

論地方自治團體之憲法訴訟權 —— 德國法之比較

黃錦堂*

目 次

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 壹、前言 | 伍、地方自治團體之聲請統一解釋法令？ |
| 貳、地方立法或行政機關提起「法規範憲法審查」 | 陸、就審查所依據的憲法條文與控制密度 |
| 參、地方自治團體之裁判憲法審查 | 柒、結語 |
| 肆、國家最高機關就下級機關行使職權適用法規範之主動或被動聲請憲法審查 | |

〔責任校對：莊佩芬〕。

* 國立臺灣大學政治學系、公共事務研究所合聘教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/82110102.pdf>。



壹、前言

地方自治團體聲請釋憲，為憲法學的一個議題，晚近因為年金改革案有五個地方政府聲請解釋憲法與統一解釋遭司法院大法官決議不予受理，而引發關注¹。

地方自治團體之聲請憲法解釋，涉及憲法與法律規定。立法院於民國107年12月18日三讀通過「憲法訴訟法」，明定自公布後三年施行，取代「司法院大法官審理案件法」²，但地方制度法並未修改。為求聚焦，本文將針對憲法訴訟法的規定，討論解釋適用上的問題，也略指出地方制度法規定的問題。

地方自治團體聲請釋憲或提起憲法訴訟，係以地方自治團體享有此等權利為前提，司法院多號解釋就此已經指出這是源於地方自治團體為我國憲法所保障的制度，亦即「制度保障說」³。憲法訴

1 參見司法院大法官第1481次會議不受理決議第一〇、一一、二三、二四、二八案摘要，司法院，2018年8月10日，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=358086>（最後瀏覽日：2018年8月14日）：「聲請案號：1. 第一〇案：107年度憲一字第1號，聲請人花蓮縣政府、金門縣政府；2. 第一一案：107年度憲一字第7號，聲請人連江縣政府；3. 第二三案：107年度憲一字第5號，聲請人新北市政府；4. 第二四案：107年度憲一字第8號，聲請人南投縣政府；5. 第二八案：107年度憲一字第6號，聲請人苗栗縣政府。」

2 主要的改革，依司法院網站，包括：大法官審理案件以全面司法化為取向，採取裁判化及法庭化之方式，以嚴謹訴訟程序與法院性質之憲法法庭運作模式，並以裁判方式宣告審理結果；合理調降憲法審查案件之表決門檻，並採主筆大法官顯名制，俾有效提升審理案件效能；建立「裁判憲法審查」制度，使大法官憲法審查效力擴及於法院確定終局裁判，提供人民完整而無闕漏之基本權保障；明定總統、副總統彈劾案件之審理規定，並採相對高密度規範，以審慎維護國家憲政秩序之安定；設地方自治保障案件專章，強化其憲法制度性保障；衡酌新舊法制接軌對當事人權益保護之必要與兼顧法之安定性，相應為過渡條款設計等。參見司法院第167次會議通過「憲法訴訟法」草案新聞稿，司法院，2018年3月26日，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=323443>（最後瀏覽日：2018年12月24日）。

3 司法院釋字第498號解釋文指出「地方自治為憲法所保障之制度。司法院釋字第550號解釋文指出：地方自治團體「受憲法制度保障」，其施政所需之經費負擔乃涉及財政自主權之事項，固有法律保留原則之適用，但於不侵害其自主權

訟法第83條理由欄二（三）指出「衡諸地方自治團體應受憲法制度保障」，但也指出「地方自治團體既係基於憲法所保障之地方自治權受侵害，類同於人民憲法所保障之基本權受侵害」，這兩者照理說有所區別，但「類同」何在？於憲法訴訟上應有如何不同之對待？地方自治團體非聯邦國家之邦，地方行政或立法機關非國家憲政機關，果爾，則地方行政或立法機關可否直接起訴（憲法訴訟法第82條）？就委辦事項，地方只能經由國家最高行政機關起訴，懇求「慈悲」，見憲法訴訟法第47條，這根本問題在於，地方可否主張，委辦事項之法律規定過當，而侵害其憲法上之自治權？憲法訴訟法第八章為「統一解釋法律及命令案件」，第84條規定：人民就其「依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判適用法規所表示之見解，認與不同審判權終審法院之確定終局裁判適用同一法規已表示之見解有異」，得聲請憲法法庭為統一見解之判決，顯示並不允許地方機關之聲請，這是否合於憲法地方自治保障？

國內有關地方自治團體的憲法訴訟權的著作尚屬有限，德國法的比較不足⁴。本文將檢討地方制度法、司法院大法官審理案件

核心領域之限度內，基於國家整體施政之需要，對地方負有協力義務之全民健康保險事項，中央依據法律使地方分擔保險費之補助，尚非憲法所不許。」（上下引號為筆者所加）其中所稱財政自主權、法律保留、非核心領域（有別於核心領域）、國家出於正當事由之干預、比例原則、立法裁量，整體而言係以職掌、權限劃分而為論證，未提及基本權。司法院釋字第738號由業者於窮盡訴訟途徑後提出聲請。解釋文指出，電子遊戲場業申請核發電子遊戲場營業級別證作業要點規定，電子遊戲場業之營業場所應符合自治條例之規定，兩個地方自治條例之限制設置地點規定，「皆未違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則」，也未言及基本權。

- ⁴ 期刊論文見，吳信華，論地方自治團體的聲請釋憲，政大法學評論，87期，頁133-190，散見各處（2005年）。該文儘管指出德國有聯邦體制之爭議、地方自治團體的憲法訴願、憲政機關間之權限爭議，但沒有逐一檢視，而以我國地方制度法與司法院大法官審理案件法之釋義為關懷，討論二法的關係、地方制度法於適用時應否準用司法院大法官審理案件法之類型構成要件，以及地方自治團體之提起行政訴訟與憲法訴訟之關聯性，於此主張「憲法訴訟之補充性原則」作為標準；就是以行政訴訟作為聲請釋憲的前提要件，其指出，憲法訴

法、司法院釋字第527號解釋、司法院釋字第553號解釋及憲法訴訟法，並以後者的主要規定展開討論。本文將主要比較德國「地方自治團體之憲法訴願」，特徵為主觀訴訟、規範違憲審查、原則上應窮盡訴訟程序、以地方自治團體憲法上的保障規定作為審查依據與標準；除此之外，因事涉制度保障而非基本權保障，所以憲法法院原則上應調降控制密度，本文也將一併討論。

本文屬於法釋義學之研究，前言中指出我國的規定與問題。然後依序針對憲法訴訟法第82條就地方立法或行政機關權限爭議（第貳節）、憲法訴訟法第83條地方自治團體之裁判憲法審查（第參節）、地方聲請釋憲或統一解釋（第肆節），其中將進行德國法之比較；然後為憲法庭之審查依據與控制密度（第伍節）；最後為結語（第陸節）。

地方自治保障屬於憲法與行政法的重要議題之一。吳庚教授高度關注，除了「制度保障說」之外，進一步指出「自治內涵」包括組織及人事權、財政權、地方立法權及自治之監督與救濟⁵；當地方自治團體「作為統治組織之一部分時，固無訴權之權能」⁶，就公法人之身分提起訴願，應限於公法人基於法律規定所享有之權益⁷；就公法人是否享有基本權能力，指出奧國以公法人的「作為」究屬公權力或私經濟行為作為判斷標準，於從事私經濟活動

訟僅涉及憲法問題而非一般的審級救濟途徑，故行政爭訟途徑與憲法爭訟途徑二者間，在自治團體之監督救濟程序中係各自獨立，不應將行政訴訟途徑視為聲請釋憲之必然前提要件。至於「法人」於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者之聲請釋憲，其指出應不包括公法人在內，所以當然不包括地方自治團體，理由為地方自治團體是公法人，並不是自然人，原則上無法為基本權利之主體。對於地方機關依司法院大法官審理案件法第7條第1項第1款之聲請統一解釋法令，該文並未針對統一解釋法令之得失進行檢討。

5 吳庚，陳淳文，憲法理論與政府體制，增訂5版，頁703-768（2017年）。

6 吳庚、張文郁，行政爭訟法論，修訂8版，頁68（2016年）。

7 吳庚、張文郁（註6），頁68-70。

時，公法人係享有基本權保障，德國法過於嚴苛，而我國實務運作到現在為止，事實上與奧國作法相近⁸。

吳庚教授學術底蘊深厚，堅持憲政主義理想，抱持「實踐理性」態度，積極參與釋憲工作並著書立說，哲人已逝，令人緬懷！

貳、地方立法或行政機關提起「法規範憲法審查」

一、條文規定與理由

憲法訴訟法第82條規定：「地方自治團體之立法或行政機關，因行使職權，認所應適用之中央法規範牴觸憲法，對其受憲法所保障之地方自治權有造成損害之虞者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」（第1項）。「前項案件，準用第五十條至第五十四條規定」（第2項）。其理由欄指出，本條參照司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款。其次，理由欄三指出，本條第1項案件，「性質屬法規範憲法審查」，「類似本法第47條國家最高機關聲請案件」⁹，關於其聲請書之記載事項、判決主文之諭知等規定，均可援用，爰有第2項準用規定。

應注意者為，司法院院會於2013年版通過司法院大法官審理案件法修正草案。司法院大法官審理案件法修正草案第84條規定地方

⁸ 吳庚、陳淳文（註5），頁134-135。

⁹ 憲法訴訟法第47條規定：「國家最高機關，因本身或下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」（第1項）。「下級機關，因行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得報請上級機關為前項之聲請」（第2項）。「中央行政機關組織基準法所定相當二級機關之獨立機關，於其獨立行使職權，自主運作範圍內，準用第一項規定（第3項）」。^又，憲法訴訟法第48條規定：「前條之法規範牴觸憲法疑義，各機關於其職權範圍內得自行排除者，不得聲請」。

自治團體就中央「法規範」聲請憲法審查：地方自治團體因行使職權，認所應適用之中央法規範牴觸憲法，對其受憲法所保障之地方自治權有造成損害之虞者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決，從而與憲法訴訟法所採「地方立法或行政機關所提起之機關爭議」不同；本草案與德國「地方自治團體之憲法訴願法」也有不同，後者原則上須窮盡訴訟途徑¹⁰。

憲法訴訟法第82條立法理由欄指出本條係參考司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款之規定，顯示繼受自原有規定，對外國法的比較稍有不足。

二、是否為抽象的規範違憲審查？——德國法得起訴者限於聯邦政府、邦政府、四分之一聯邦眾議員之連署

憲法訴訟法第82條係指稱一種抽象的規範違憲審查，蓋其並不以存有機關間之個案爭議或繫屬於法院為前提。

（一）德國之抽象的規範違憲審查

在比較法上¹¹，若從德國法「抽象的規範違憲審查」以觀，依聯邦基本法第93條及聯邦憲法法院有關之文，得提起本訴訟者為聯邦政府、邦政府、四分之一以上之聯邦眾議院議員人數經連署，以上的名單係終局，而不得經由解釋或類推適用而加以擴張。除此之

¹⁰ 另得一併觀察者，為2013年版司法院大法官審理案件法修正草案第85條「地方自治團體就權限或事權爭議聲請判決」：「地方自治團體因行使職權，與中央機關或其他地方機關發生憲法上權限之爭議，或憲法適用上之爭議，於依地方制度法第77條協商未果後，認對其受憲法所保障之地方自治有造成損害之虞者，得聲請憲法法庭為機關爭議之判決」。本文認為，地方自治團體與其他地方機關間，不會發生憲法上的權限爭議，蓋雙方認事用法作成決定，即使有爭議也屬於行政法層次。

¹¹ 此處與以下，Gerd Morgenthaler, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, 42. Edition, Stand: 01.12.2019, Art. 93 Rn. 26 ff.; Jochen Rozek, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.) Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Stand: Lfg. 52 September 2017, § 76 Rn. 1 ff.

外，提起本訴訟必須係就該規範違憲與否的釐清，存有「一個特別的客觀上的利益」(ein besonderes objektives Interesse)；這非謂聲請人必須有一個主觀權利的保護利益，蓋本訴訟類型在德法上仍然界定為一種「客觀訴訟」，主要構想在於讓憲法法院作為憲法守護人(als Hüter der Verfassung)的任務能夠發揮。本訴訟類型無須有程序相對人(Antragsgegner)，也沒有起訴的期限(Antragsfrist)¹²。作為客觀訴訟，本訴訟不以聲請人的主觀權利受侵害為前提，但至少必須其就系爭規範是否合憲是否存疑，或與其他的邦政府或聯邦政府之間存有不同的意見；正是在這個意義上，聯邦憲法法院必須審查起訴有無釐清之意義。就系爭規範的是否具有合憲的懷疑，必須具有一種實務上的重要性(von praktischer Relevanz)，若只是學術上的爭議或假設性的疑義，則不被允許¹³。依德國基本法第93條第1項第2款及聯邦憲法法院法第13條第6款，抽象的規範違憲審查的審查標準：若係聯邦法律有無抵觸基本法之爭議案件，則為基本法條文；若係邦法有無違反聯邦法，則審查標準為聯邦法律。除此之外，由於本類訴訟屬於客觀訴訟，所以聯邦憲法法院得針對系爭的規範從所有的憲法的觀點加以審查，而無須受制於聲請人所提出的論點。若系爭規範屬於行政命令，則聯邦憲法法院也得審查其是否有一個充分的法律授權。若聯邦憲法法院的審查結果確認該系爭規範與聯邦法律或基本法不合，則其應宣告該規範無效；但另一方面而言，也應考量到立法者的形成自由及其他的衡量，在實務上也得經由部份無效、不合憲、或一個警告性的裁判、或以合憲性解釋方式，而為替代或補充¹⁴。

12 Morgenthaler (Fn. 11), Art. 93 Rn. 26 f.

13 Morgenthaler (Fn. 11), Art. 93 Rn. 34 f.

14 Morgenthaler (Fn. 11), Art. 93 Rn. 28 f.

三、是否為機關爭議？——德國法機關爭議限於憲政機關始得提起，不包括地方機關

憲法訴訟法第82條理由欄三指出，本條第1項案件，「性質屬法規範憲法審查」，「類似本法第47條國家最高機關聲請案件」¹⁵。

德國法有所謂「憲政機關間之權限爭議」(Organstreit)。依德國基本法第93條第1項第1款，其係指就某一「聯邦最高機關」或「機關之部分」或「其他當事人」之權利義務範圍發生基本法解釋上之爭議。得起訴之主體有三種：首先為聯邦最高機關；其次為擁有自己的權利之聯邦最高機關之部分 (mit eigenen rechten ausgestattete Organteile)；第三為德國基本法第93條第1項第1款所稱之其他當事人 (andere Beteiligte)。所謂聯邦最高機關，係指本身不隸屬於另一個國家機關而且存續，及職掌主要直接來自基本法規定之聯邦機關，包括聯邦總統、聯邦眾議院、聯邦參議院、聯邦政府、「聯邦之總統選舉人團」(Bundesversammlung)。「擁有自己的權利之聯邦最高機關之部分」係指其自身經由基本法或聯邦最高機關的處務規程規定而享有憲法上權利者，例如聯邦眾議員議長（有關行使議長職權）、聯邦眾議院調查委員會、聯邦眾議院之情治機關監督委員會等、黨團、個別議員，聯邦參議院議長（有關行使議長職權）、各委員會、個別參議員，「聯邦眾議院與參議院之共同委員會」(Der gemeinsame Ausschuss)，聯邦內閣總理及部長。「其他之當事人」則為「政黨」、聯邦審計院等¹⁶。

¹⁵ 憲法訴訟法第47條規定：「國家最高機關，因本身或下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有抵觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」(第1項)。「下級機關，因行使職權，就所適用之法規範，認有抵觸憲法者，得報請上級機關為前項之聲請」(第2項)。「中央行政機關組織基準法所定相當二級機關之獨立機關，於其獨立行使職權，自主運作範圍內，準用第一項規定」(第3項)。又，憲法訴訟法第48條規定：「前條之法規範抵觸憲法疑義，各機關於其職權範圍內得自行排除者，不得聲請」。

¹⁶ Vgl. Axel Hopfau, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfau (Hrsg.), GG Kommentar, 11. Aufl., 2008, Art. 93 Rn. 93; Hans Dieter Jarass/Bodo Pieroth, in: Jarass/Pieroth

以上顯示，本訴訟之主體並不包括地方立法或行政機關。

本訴訟屬於兩造對立之程序（*ein kontradiktorisches Verfahren*），爭執的客體為系爭措施，有無違反基本法規定，而侵害或直接危害（*Verletzung oder unmittelbare Gefährdung*）聲請人之憲法上所規定的權利¹⁷。

文獻指出，機關爭議為政治性之制度（*politisch aufgeladen*），旨在解決憲政機關間之爭端，可謂係對政治性爭議的司法處理（*Juridifizierung der Politik*）¹⁸。就機關爭議制度早先曾存有不同意見，例如擔心其是否旨在對政治（行動）進行司法化審查，但當今多數說認為¹⁹，當憲政機關相互間經由各自行為劃定權限釐清爭議之機制，於一時間因故無法發揮功能時，以及出於對少數者之權利保障而言，這都是無可捨棄的一項機制；對於憲政機關間權限劃分的釐清不只是在於解決紛爭，也是對於國家最高層次的統治權運作，能夠經由判決而逐步取得更多的認識與具拘束力之標準，以便能夠對於國家統治權行使之法治化追求獲得進展²⁰。

本文認為，機關爭議由最高且最具權威的憲法法院作為管轄機關，一審終結，旨在快速、具權威、有效釐清爭議，否則長期以往將造成國家與社會發展上的困擾，而且在實務上，這機制也已經發展成為對少數的保障。地方自治團體為憲法明文保障，但畢竟為地

(Hrsg.), GG Kommentar, 13. Aufl., 2014, Art. 93 Rn. 5-7.

17 本訴訟必須存有一個被爭執的客體，而這係指稱一個措施或不作為，後者必須是憲法上規定被告機關負有行為義務者；兩造的權利義務必須具有對立性（*gegenseitig*），而且是來自憲法的規定，包括明文或是儘管未明文但得經由解釋而得出；若只涉及法律層次之權利義務，則不該當；vgl. etwa *Jarass/Pieroth* (Fn. 16), Art. 93 Rn. 8.

18 Vgl. *Max-Emanuel Geis/Heidrun Meier*, Grundfälle zum Organstreitverfahren, Art. 93 I, Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 ff. BVerf GG, JuS 2011, S. 699 (700).

19 Vgl. *Geis/Meier* (Fn. 18), S. 700.

20 於此得補充者為，若系爭爭執已經有法律加以規定，則原告也得直接就之提起抽象的規範違憲審查。

域性（從而為功能性），地方自治團體數目頗多，又可分為不同層級（例如縣市、鄉鎮市），整體而言與國家之間的角力不是高激烈性、高政治性，而與邦憲政機關相互之間不同，所以一般而言不需要機關爭議之衝突解決，最多可考慮特殊領域或類型，例如針對國家之財政收支劃分權限（規定）。

四、地方機關提起憲法爭議，是否參考自聯邦體制爭議？

我國憲法訴訟法就地方憲法自治權保障引進「機關爭議」的參考依據，除了憲政機關爭議之外，另一種可能係「德國聯邦與邦之憲法爭議」，這也是由聯邦政府或邦政府直接提起。以下略作討論。

這爭議廣義而言包括兩大類，一是「抽象的規範違憲審查」，由邦政府提起，主張聯邦法律違反基本法之聯邦與邦之間的權限劃分規定，或由聯邦政府提起，主張邦法律違反聯邦法律；爭執的對象為聯邦或邦之「法律」；換言之，若已經有法律規定，則得以規範違憲方式而為爭執。第二種情形，則是狹義之「聯邦國爭議」，爭執的客體並非法律，而是聯邦與邦之權限措施。

（一）針對聯邦與邦之法律

這是規範違法或違憲之審查，下位類型有三，均為「客觀訴訟」，聲請人起訴無須有「對造」（Antragsgegner）；無起訴期間限制，無「失權效」；邦政府起訴無須取得聯邦參議院之同意²¹。

1. 若聯邦與邦之間就聯邦法律、邦法律或二者之聯合，就形式上（*förmlich*）或實質上（*sachlich*）是否合於基本法規定，或邦法律是否合於聯邦法律，存有不同意見或懷疑（*Meinungs-*

²¹ Hartmut Maurer, Staatsrecht I: Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, 6. Aufl., 2010, § 20 Rn. 76; Jarass/Pieroth (Fn. 16), Art. 93 Rn. 19.

verschiedenheiten oder Zweifeln)，由聯邦政府、邦政府或四分之一的聯邦眾議院議員提出申請（第2款）。

於此，起訴所爭執者不必為基本法之聯邦與邦之權限劃分條文，所以範圍非常寬廣。其次，「不同意見或懷疑」係十分寬鬆之要件，聲請人不須於之有所參與（*daran beteiligt*），但單純之理論上衡量或質疑則尚不該當；聯邦憲法法院法第76條規定，必須申請人認為系爭規定有如上違反而該當無效，或認為有效而其他之聯邦或邦機關卻以之為無效而不予適用。第三，為避免濫訴，儘管當事人不須主張權利受侵害，但應有「客觀上之釐清利益」（*ein objektives Klärungsinteresse*）²²。案例約如，聯邦憲法法院1998年1月28日判決，基於邦政府之起訴，就「聯邦邊境保護署」（*Bundesgrenzschutz*）之組織法有關職掌中，包括賦予鐵道及機場航空安全管制任務執行之條文，其是否逾越基本法「聯邦邊境保護事項」之範圍²³。

2. 就基本法之「聯邦與邦之立法權劃分」當中「聯邦出於必要而制定聯邦法律之審查」（*Kontrolle der Erforderlichkeit von Bundesgesetzen*）：相較於前者，本類型也是針對聯邦法律，但爭執點為基本法之聯邦與邦之立法權劃分規定。就聯邦制定之法律是否合於德國基本法第72條第2項要件，亦即，「為了於整個聯邦區域建立同等級的生活關係，或為了整體德國利益而創造一個法律與經濟之單一性，而有必要聯邦以法律為規定」，若聯邦與邦存有不同意見（*Meinungsverschiedenheiten*），則聯邦參議院、邦政府或邦議會得提出申請（第2a款）。

²² *Maurer* (Fn. 21), Rn. 81 f.

²³ BverfG, Beschluss des Zweiten Senats von 28. Januar 1998 – 2 BvF 3/92 –, Rn. 1-111, http://www.bverfg.de/e/fs19980128_2bvff000392.htm.

3. 就如上2，於聯邦完成立法並施行之後，聯邦參議院或邦政府或邦議會得提出申請，確認前述要件不復存在，而由邦法律取代。

(二) 針對聯邦與邦之憲法上權利義務爭議

本訴訟類型的標的，為法律以外之行為違反基本法規定，主要為聯邦對邦之監督行為。

1. 概說：聯邦與邦之分立、事項劃分與權限劃分

德國為聯邦體制國家，聯邦與各邦均具有「國家」屬性，雙方的權限劃分規定於基本法，可分為立法權、執行權（也可稱為行政權）、司法權、財政權，除此之外尚有些許項目是屬於聯邦與邦之「共同任務事項」（*Gemeinschaftsaufgaben*）。制憲者將諸多的事項/權限分別劃歸聯邦或邦，並且也規定一定的機制，使聯邦與各邦各有業務權責，相互之間有一定的唇齒銜接（*einander zuordnen und miteinander verzahnen*）。換言之，聯邦與邦之間有諸多相互影響可能性或相互影響性權力（*Einwirkungsrechte*）。

這些相互間影響力機制約為；首先，就邦所得行使者為：1. 邦得經由聯邦參議院，而於聯邦之立法與行政上及歐盟事項上享有參與權。聯邦參議院保有諸多不同形式的參與權。就立法權而言，最強的模式係於聯邦眾議院三讀通過之後保有「同意權」。2. 邦也得聲請聯邦憲法法院作出裁判，亦即，針對聯邦法律或其他措施，以違反基本法之「聯邦－邦的權限規定」為理由（德國基本法第93條第1項第3、第4款）。這須以侵害邦之基本法所保障權利作為前提；除此之外，邦也得依德國基本法第93條第1項第2款提出抽象的規範違憲審查，無須以邦憲法上的權利受侵害為要件²⁴。

²⁴ Maurer (Fn. 21), § 10 Rn. 41 ff.

至於聯邦所得行使的影響性權力，則包括：1. 聯邦得制定法律，對邦及邦之機關具有拘束力，而得於相當程度調控聯邦與邦之間的有關政策。2. 聯邦對邦之執行聯邦法律，不論係以邦自身事項或以聯邦委辦事項而為執行，聯邦享有不同強度的監督權。3. 聯邦得以邦侵害聯邦的權利，而向聯邦憲法法院提起「聯邦－邦之爭議」；除此之外也得針對邦法律，以違反基本法或違反聯邦法律，提起抽象的規範違憲審查。4. 聯邦有權貫徹德國基本法第28條「邦之憲法秩序必須合乎基本法」之規定。5. 在自然災害或其他對公共秩序安全重大危險之情形，或對邦之存續或對邦之自由民主基本秩序之危害，邦得請求聯邦提供補助，必要時也得要求聯邦派出警察部隊等。6. 聯邦得行使「聯邦強制」：若邦不能履行其依基本法或聯邦法律所課予的義務，則聯邦政府依據德國基本法第37條聯邦強制之規定，採取必要措施，以促使邦履行憲法上義務。7. 就以上相互對待或權限行使，基本法進一步規定聯邦與邦必須貫徹「對聯邦友善之行為義務」（Der Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens），也稱為「聯邦忠誠原則」（Grundsatz der Bundestreue）。由此得導引出一定的聯邦或邦之權限行使上限制，或參與義務或程序要求，甚至是作為或不作為義務，或為一定之自我節制（Zurückhaltung）²⁵。

2. 聯邦國之權利義務爭議

聯邦國之權利義務爭議（Föderative Streitigkeiten）為具「聲請人」與「對造」之類型（Kontradiktorische Verfahren）。有權提起者為聯邦與邦，由聯邦憲法法院管轄，作成「確認判決」（Feststellungsurteil）²⁶。

²⁵ Maurer (Fn. 21), § 10 Rn. 44-54.

²⁶ Vgl. Maurer (Fn. 21), § 10 Rn. 53, 62 ff.

本訴訟得有三種下位類型，一是聯邦與邦之權利義務爭執；二為「邦之間的公法上爭議，而無其他法院管轄」²⁷。三是「邦內部之公法上爭議，而無其他之法院管轄」(Landesinterne Streitigkeiten)²⁸。以下僅針對第一種。

所謂「權利」或「義務」，須憲法所規定，而不是基於法律所生，後者依德國行政法院法(VwGO)第50條第1項由聯邦行政法院為第一審之管轄²⁹。儘管法條要件為「對於聯邦或邦之權利義務存有不同意見」(Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder)，但經由解釋與實務發展，起訴者須主張憲法上所建立的權利受到侵害(Geltendmachung der Verletzung eines verfassungsrechtlich begründeten Rechts)，所以非客觀訴訟³⁰。本類型須涉及具體爭議(ein konkreter Streit)；若只是單純之意見不同或對法律規定的解釋不同，則並不該當。當事人提出聲請的期限，為六個月，從知悉系爭措施或不作為之日起算。本訴訟須有「權利保護之必要」(Rechtsschutzbedürfnis)；即使系爭爭議已經結束，不意味原告不再享有權利保護必要；但若相關案型再度發生係完全不可能，則又另當別論。本訴訟的爭執客體，為「聯邦或邦之基本法上權利或義務之爭執」，包括直接之聯邦與邦權限規定、「聯邦忠誠原則」、其他非直接之權限劃分規定但引發權利義務爭執者，例如聯邦依德國基本法第23條有權參與歐洲聯盟機關之決

27 其要件與「聯邦與邦之間的爭執」相近，不同者為聲請者與被聲請者均為邦政府，爭執的客體為邦所享有的權利(權限)。聯邦與邦的權限爭議，聯邦憲法院係作成確認判決，但就邦與邦之間的權限爭議則解釋上也得作成「課予義務判決」(Verpflichtungsurteil)，例如要求被告之邦政府必須或不得採行一定的措施，或必須容忍，或必須提供一定的給付。

28 這種爭議在解釋上必須是具有邦憲法意涵者，常見者為邦憲政機關間之權限爭議。其屬於邦內部而竟然成為聯邦體制爭議，係因此種爭議很有可能外溢而對聯邦國造成影響。

29 Christoph Degenhart, Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 29. Aufl., 2013, Rn. 824.

30 Maurer (Fn. 21), § 20 Rn. 56.

定而未能充分顧及邦之參與權³¹。

3. 聯邦法律之交付邦執行及聯邦監督權之憲法規定

這是聯邦體制爭議之常見類型，基本法有專門規定。這訴訟外型上與「單一國」之中央對地方自治團體監督有若干近似。

在德國，絕大多數的聯邦法律係交由邦執行，分為兩種情形：一是「作為邦自己之事項」而委託執行（als eigene Angelegenheit），屬於原則，見德國基本法第83條，於此邦享有較大的權限；二是例外情形，限於基本法明定，聯邦法律係以「作為聯邦委辦之事項」而委託執行（Bundesauftragsverwaltung），於此聯邦政府有權制頒一般性之行政規則，邦行政機關於執行聯邦法律，須受聯邦最高主管機關指令之拘束，聯邦的監督權限涵蓋執行行為之合法性與合目的性³²。依德國基本法第84條，若邦係以自己的事項而執行聯邦法律，則邦有權自行規定行政機關的設置以及所應適用的行政程序；若聯邦法律中已經明文有特別的規定，則邦得制定偏離之規定（abweichende Regelungen）；於例外情形，聯邦得基於特別的需要，制頒一致性之行政程序規定，邦不享有偏離的立法權，但須取得聯邦上議院之同意；聯邦政府於取得聯邦上議院的同意，也制頒一般性的行政規則；除非聯邦法律明文規定，而且須取得聯邦上議院的同意，聯邦政府得被授權，對於特別案例有權制頒個別指令。若邦係以執行聯邦委辦事項的身分而為執行，則就有關機關如何設置邦的機關權限仍然歸屬於邦，除非該聯邦法律經取得聯邦參議院的同意而有特別規定；聯邦政府於取得聯邦上議院的同意，得制訂一般性的行政規則，並得對相關公務人員與契約進用

³¹ Axel (Fn. 16), Rn. 126, 131.

³² 基本法明文規定之委辦事項，例如：有關核能電廠之管制、有關航空運輸之行政、有關聯邦水道之管理使用、有關聯邦遠距離道路事項、有關聯邦財政補助之委託邦執行、有關負擔平衡之執行（Lastenausgleich）。

人員之養成加以規定；邦執行該聯邦法律之中級行政機關之行政首長（Die Leiter der Mittelbehörden）應取得聯邦政府的同意後始得任命（德國基本法第85條第2項）；邦行政機關必須遵守聯邦最高機關之指令；指令的對象，為邦的最高行政機關（按，旨在避免邦最高行政機關之領導統御權遭架空），但若聯邦政府認為情勢急迫，則不在此限；對聯邦政府所作指令，邦之最高行政機關應確保執行（德國基本法第85條第3項）；聯邦之監督涵蓋執行行為之合法性與合目的性；聯邦政府為此目的得要求邦主管機關提交有關的文件，聯邦也得派遣專案受委託人到邦之所有的行政機關（德國基本法第85條第4項）。以上的權限劃分與監督規定，因運用得廣，有可能產生爭執，知名案例為1990年5月22日聯邦憲法法院卡爾卡核電廠判決，針對聯邦政府指令之合憲性³³。

³³ 爭點概為，依德國基本法第87c條，「核能製造利用法」（約為我國之「原子能法」）為聯邦委辦事項，交由邦執行。本件核能電廠係採「部分許可制」方式，由邦主管機關發照，將整個設廠案區分為若干部份，業者必須逐一取得許可。此一制度的優點，在於避免整個核電廠採「一次發照」方式，蓋這過於粗糙，對業者與行政機關而言都是負荷過重，對公共安全而言也存有審查不周之危險或疑慮，對業主則是「一次定輸贏」，風險過高。本件已經作出17個局部許可，於進入第18個之審查時，因為蘇聯境內發生「車諾比核電廠災難事件」，導致德國居民恐慌，輿論也有諸多質疑，該核電廠所在之北萊茵—西伐利亞邦之環保部長乃要求業者，應就該廠重新提供一個整體性合乎核能法要求之評估報告，其中須針對車諾比事件原因而檢視既有技術安全之問題。業者認為，這樣的要求毋寧近乎撤銷先前之諸多部分許可，構成莫大負荷與經營上之不確定性，從而向聯邦主管部提出申訴或要求介入。聯邦與邦之主管部長們經懇談後仍無法達成一致性見解。聯邦主管部長乃依德國基本法第85條第3項規定，作出指令，內容涵蓋三大方面，邦政府起訴，主張系爭指令違反基本法第2條第2項「人民的生命與身體不可侵害」，第24條第1項「聯邦國原則」、第20條第3項「權力分立原則」、第30條「原則上應由邦履行聯邦國體制中之國家的權責與任務」、第85條「聯邦監督權界線」。聯邦憲法法院判決邦敗訴，理由主要為：聯邦於行使指令權時，依基本法規定涵蓋合法性與合目的性之監督。本件中，系爭指令之裁量權行使難謂有所違反。基於「聯邦友善性行為之義務」，聯邦於作成指令決定前，應給予邦意見陳述的機會，也應將邦所提意見於決定中納入考量；若聯邦最後決定採取指令權，則也應對邦先行預告；指令的內容必須合乎明確性；指令須向最高主管機關作出，以便其得依行政層級向下屬作出指示，除非有急迫情形。聯邦體制的權力限制規定並不涉及個人的權利保護，所以個人基本權規定並不適用，尤其人權干預違憲審查之比例原則。就判決要

（三）小結

以上顯示，德國聯邦與邦的權限爭議，得分為針對法律或針對非法律；後者針對基本法之任何聯邦與邦之關係規定，其中的大宗案件，為邦執行聯邦法律所引發者，這在我國約可比擬為地方自治團體執行自治或委辦事項之受到上級機關監督，但因為聯邦體制而拉高為憲法訴訟。反之，德國各邦之內，地方自治團體辦理自治或委辦事項受到上級機關之不利的監督處置，則其原則上必須經由行政爭訟程序尋求救濟。

五、我國規定之檢討

經由以上比較，吾人得檢討我國立法政策得失並針對要件進行解釋。

1. 制度之定位

我國地方自治團體的數目頗多，即使憲法訴訟法第82條理由欄所稱起訴主體限於直轄市、縣市，總共也有19個之多（六個直轄市、三個省轄市、十三個縣——包括福建省連江縣與金門縣）。我國部會層級只有獨立機關得起本訴訟（憲法訴訟法第47條第3項），其他必須報請上級機關提出聲請，果爾，則個別直轄市、縣市立法或行政機關竟然等同於憲政機關而得起訴，有無憲法上依據，有無過度造成憲法法院之負荷，於我國當今地方與中央可能由不同政黨執政而且因為「中央之總統與立法委員舉」及「地方之九合一選舉」選戰發生激烈較勁抗衡情形下，相關考量有無失衡？

其次，我國非聯邦國家，無須採行聯邦體制爭議，所以無須由

旨，參見BVerfGE 81, 310 = NVwZ 1990, S. 955; vgl. Maurer (Fn. 21), § 18 Rn. 15-18; Andreas Voßkuhle/Anna-Bettina Kaiser, Die Ausführung von Bundesgesetzen - Verwaltungskompetenzen, JuS 2017, S. 316 (317 f.).

地方政府直接提起憲法訴訟。約言之，我國制憲當時對省與縣採高度保障，儘管制憲當時曾有「省得制定省憲」之說，但未入憲，改以省得依據省縣自治通則制定「省自治法」、「縣自治法」，作為各省、縣自治之基本法律，以及省議會、縣議會享有立法權。憲法進一步於憲法第114條規定「省自治法制定後，須即送司法院。司法院如認為有違憲之處，應將違憲條文宣布無效」(這是一種抽象的規範違憲審查，非「主觀訴訟」之意義)，於憲法第117條「省法規與國家法律有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之」(於此並未規定聲請之主體，以及類如憲法訴訟之訴權、起訴期間、權利保護必要等要件)，甚至於憲法第115條「省自治法施行中，如因其中某條發生重大障礙，經司法院召集有關方面陳述意見後，由行政院院長、立法院院長、司法院院長、考試院院長與監察院院長組織委員會，以司法院院長為主席，提出方案解決之」，以因應省之高度自治保障。政府遷臺後並未依據憲法制定前述通則，而且於第二次修憲時凍結憲法「省縣自治通則」規定，授權立法者直接制定地方有關制度，1997年修憲進行「精省」，省的自治保障遭到凍結，已經高度走向「單一國」體制³⁴。既然如此，則地方自治團體與國家之

³⁴ 學者蘇永欽指出，我國地方自治的憲法定位得分為三個階段。民國81年增訂憲法增修條文以前，屬於第一階段，特色為「憲制層次很高，法制程度很低。第二階段為「全面法制化，但憲法層次降低」，亦即民國81年憲法增訂增修條文第17條之後的發展，其規定省縣地方制度以法律定之，並明文規定省自治之監督機關為行政院，縣自治之監督機關為省政府。地方自治的憲法定位也起了本質的變化。簡言之，就是從憲法保留往法律保留移動。省縣的自治權雖然還在憲法保障範圍，並未遭到停止適用，但地方組織法的制定權已經完全收歸中央。而正因為第十章的權限劃分有極大的灰色領域，此一組織訂定權已使中央對灰色地帶的分配取得更絕對的主導地位。第三階段為廢除省自治，地方自治法制，進一步由中央主導，指民國86年第四次修憲起。省之自治遭到凍結，原來賦予省的補充立法權——具有競合立法權的實質而為調和中央與省縣權限的樞紐，也隨同自治的廢除不復存在，縣的自治權限雖仍受憲法保障，但其本來就十分有限，且沒有任何主動補充權，而大大限制了法規創造力的發揮空間。地方制度法改以大一統的方式規範三種自治團體，所謂其他依法律賦予之事項(地方制度法第18、19、20條的最後一款)，遂成為左右地方自治廣狹的活瓣，完全操之於中央。當地方自治，除了組織及運作完全在中央立法權主導下之

間的爭訟，不管權限移轉或是地方立法權（含自治條例、自治規則、委辦規則）、地方議會議決自治事項、地方政府之執行個案（可分為自治或委辦事項），原則上沒有必要由司法院大法官直接受理。

2. 本條究竟屬於主觀或客觀訴訟？

我國憲法訴訟法第82條的理由欄指出「性質屬法規範憲法審查」，「類似本法第47條國家最高機關聲請案件」。就國家最高機關聲請聲請案件，其起訴「因本身或下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」，不以權利受到侵害或有受侵害之虞為要件，所以是客觀訴訟。對照行政訴訟法第4條第1項的起訴要件「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為『損害』其權利或法律上之利益」，憲法訴訟法第82條不以權利受侵害為要件，而是「受侵害之虞」，所以也不是沒有主觀訴訟之意涵。

本文認為，個別地方行政或立法機關竟然可以直接起訴，相較於中央憲政機關、立法委員現有總額四分之一連署始得成案，不無「比重失衡」，所以應朝向主觀訴訟而為解釋。於此得比較者為，德國法「地方自治團體之憲法訴願」，性質上為規範違憲審查，採主

外，連自治範圍的大小，實質上也由中央來操控時，若讓地方擁有自主權衡是否及如何限制住民權利，而中央反而完全不能置喙（除了事後合法性監督），將使得法律保留模式背後的中央控制下的地方自治露出很大的破綻。理論上，當地方自治發展到高度成熟時，立法者可以充分授權地方自主決定及如何限制人權，與採議會保留無異，但差別在於自治的發展始終在中央的控制之下，而這正是前述修憲調整地方自治體制的精義；這是中央對地方自治的「宏觀調控」，不是也不當然構成對地方自治的壓抑。綜上，地方自治條例涉及人權干預時，有法律保留之適用。但這種法律的授權明確性應予降低，蓋就法理而言，把限制人權的決定權水平地委任給行政部門必須在授權要件上嚴格一點，但若委任給地方立法部門，則應予降低，考量的重點反而應集中於地方自治的成熟度。參見蘇永欽，地方自治法規與人民權利義務，收於：臺北市府法規委員會編，地方自治法2001，頁135、151（2001年）。

觀訴訟，起訴者須「自身」之憲法保障的權利、「現在」、「直接」受到侵害，我國法不採「現在」、「直接」，但必須有「之虞」，可謂為一種「放寬」之主觀訴訟。

3. 須否窮盡訴訟途徑？

本條既然是抽象的規範違憲審查，所以無須以具體個案繫屬法院為要件，遑論窮盡訴訟途徑，但這有不妥，以下略作說明。

憲法訴訟法第82條所稱「中央法規範」得包括「法律」及「非法律位階而具有外部拘束力」之規範。

若個案係涉及法規命令或其他具外部效力規範有無違反法律保留原則、授權明確性原則、違反授權範圍或授權目的之爭議，則這些均得成為行政法院之審查範圍。約言之，儘管我國未採行類如德國行政法院法（按，約如我國「行政訴訟法」）地方自治團體受憲法保障的自治權受到侵害，在訴訟安排上，得分為行政訴訟與憲法訴訟，前者又得區分為「針對行政處分之爭訟」（例如，中央主管部會依據地方制度法第75、76、77條，對於直轄市政府、縣市政府執行法律進行監督，作成個案之處置）與針對「法規命令或其他具外部效力規範」（例如國家依有關法律制頒區域計畫、自然保護區計畫、水源區域計畫）之爭訟，後者又可分為間接與直接起訴，後者我國原先沒有採行，晚近上就都市計畫法領域經大法官的解釋有所突破與修法，但也僅止於此；就中央的法規命令或其他具外部效力之規範之有無違法，我國行政訴訟法原則上不允許地方自治團體得直接提起，而須於遭受不利益行政處分時以之剛當違法為理由而起訴，而於訴訟理由中一併主張系爭規範之違法。於以上情形，地方自治團體應於窮盡訴訟途徑後始得提起憲法訴訟，蓋這得以減輕憲法法院之負荷，對於地方自治團體的權利保護也無不周。

反之，若地方自治團體所爭執者為「法律」，則因法律違憲審查非屬於行政法院的權責（但各級法院法官得以系爭裁判所適用之法律有違憲嫌疑而得暫時停止審理，聲請釋憲），而有嚴肅討論必要。在比較法上，德國「地方自治團體之憲法訴願」（*Kommunale Verfassungsbeschwerde*），性質上為「規範違憲審查」，係採主觀訴訟。地方自治團體於此須否窮盡訴訟途徑，聯邦憲法法院於個別裁判中多指出於該案尚無就之作成最終決定必要，而指出，若「具一般性意義」，亦即非限於蓋個別地方自治團體，則地方自治團體得直接起訴，例如邦財政收支劃分法³⁵。於此應注意者為，若系爭規定尚須進一步以法規命令（例如財政收支劃分法之稅收分配規定）或行政處分（例如法律規定地方議會或地方行政首長於一定要件下得被邦政府宣告解散或解職）來完成決定者，則地方自治團體的憲法上權利尚非「直接」受到侵害，亦即不該當訴權要件。另一說認為，地方自治團體的憲法訴願原則上不須以窮盡訴訟途徑為前提，蓋地方自治團體的憲法訴願係針對規範的合憲性，違憲法法院所獨享，行政法院或普通法院的審查權不及之³⁶。

本文認為，地方自治團體得直接提起規範違憲審查者，應限於「法律違憲」，其餘應先經行政爭訟途徑，憲法訴訟法第82條「中央法規範」之規定過於寬廣，不無違誤。其次，就須否窮盡訴訟途徑，或是說，就本訴訟類型有無程序「從屬性」（*Subsidiarität*）之適用，應以系爭個案有無「一般性意義」作為標準；這與個人之憲法訴願（*Individualverfassungsbeschwerde*）「窮盡訴訟途徑」之例外規定旨趣相近，亦即，若人民基本權利受侵害之憲法訴訟案件具有一般性之重要意義，或令當事人先遵循一般法院審級救濟途徑，

35 Vgl. *Matthias Dombert*, Wenn's ums Geld geht: Kommunale Finanzhoheit und die Zulässigkeitsvoraussetzungen des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes, LKV 2009, S. 343 (348).

36 *Herber Bethge*, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Lfg. 45 Dezember 2014, § 91 Rn. 50.

則其將遭受重大且無法避免之損害，則無須窮盡訴訟途徑。

以下提出一個案例，略作討論：某直轄市議會三讀通過某地方自治條例而因為其中有罰則規定而經報請上級機關核定，上級機關以該罰則違反地方制度法第26條第3項「最高以新臺幣十萬元為限」，而不予核定。若該議會針對該不予核定責成秘書處撰寫因應檢討報告，經決議交付審查會，審查結論指出本件及其他尚在審議中的自治條例案都有積極整頓，從而需要較高額罰鍰之必要，並逐一列出與說明。該直轄市議會乃經由大會決議，以其有諸多待審自治條例案均受此限制而該市確實有積極規定罰鍰以整治秩序之需要，根本解決地方制度法之上限限制，提起地方議會憲法訴訟聲請機關爭議，旨在確保憲法第110條地方立法並執行之事項及憲法第118條「直轄市之自治，以法律定之」及比照增修條文第9條第1項第4款「屬於縣之立法權，由縣議會行之」。以上，其是否合法提起機關爭議？

本文認為，地方政府已經得針對不予核定之個案監督決定提起行政爭訟。司法院釋字第553號解釋文指出：「憲法設立釋憲制度之本旨，係授予釋憲機關從事規範審查，尚不及於具體處分行為違憲或違法之審理。本件行政院撤銷台北市政府延期辦理里長選舉之決定，涉及中央法規適用在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋，屬於有法效性之意思表示，係行政處分，台北市政府有所不服，乃屬與中央監督機關間公法上之爭議，惟既屬行政處分是否違法之審理問題，為確保地方自治團體之自治功能，該爭議之解決，自應循行政爭訟程序處理」。憲法訴訟法第83條理由欄也指出：「（一）地方制度法對於地方自治團體之立法機關所議決之自治條例及自治事項，暨其行政機關所訂定之自治規則及所辦理之自治事項，設有合法性之監督機制，如有抵觸憲法、法律或法規命令等法規範，規定各該有監督權之主管機關得予以函告無效，或撤銷、變更、廢止或停止其執行（該法第三十條、第四十三條及第七十五

條參照)。(二)前揭自治監督機關認地方行政機關所辦理之自治事項，有違憲或違法情事，而予以撤銷，涉及各該法規範在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋，屬於有法效性之意思表示，係行政處分，地方自治團體對此處分如有不服，本應循行政爭訟程序解決之，由該地方自治團體，依訴願法第一條第二項、行政訴訟法第四條提起救濟請求撤銷，並由訴願受理機關及行政法院就監督機關所為處分之適法性問題為終局之判斷，業經司法院釋字第553號解釋闡釋明確³⁷。學者吳信華也指出，若地方機關單純以地方自治團體所制定的某自治條例中之規定（例如有關罰鍰的上限）遭中央主管機關不予核定，則這是地方制度法的問題，尚非憲法上的爭議³⁷。

4. 起訴之主體

本條的聲請主體為地方立法機關或行政機關。有無必要二者均得提起訴訟？

理由欄指出：「參照本法第47條聲請權應由最高機關行使之意旨，本條第1項所稱之行政機關，自係指直轄市政府及縣（市）政府」。

於此顯示，其係以（憲政）「機關爭議」為構想。就地方自治權之受侵害而言，受害者應是地方自治團體，該條條文規定「『其』受憲法所保障之『地方自治權』」，果爾，則究竟為各自者或地方自治團體者之憲法上自治權？當然，吾人也可以說，兩者各以職權行使及憲法上所保障的權利受侵害，而且地制法就二者之職權劃分有相當的規定，而區分起訴主體。問題在於，以中央新修定某法律而剝奪地方自治團體某一自治事項為例，究竟由地方立法或地

³⁷ 參見吳信華，地方自治團體對中央監督行為的爭訟途徑，台灣法學雜誌，240期，頁96-97（2014年）。

方行政機關提出？得否各自以憲法上權利有造成損害之虞為由而提出？

5. 針對「中央法規範」

地方立法或行政機關起訴時必須指明中央之「法規範」。解釋上，中央之不立法或不制訂法規命令或不予修改，若得經由解釋而界定為作為義務之違反，則地方立法或行政機關也得就之起訴。所謂法規範，不限於針對地方自治團體之監督規定，而得包括其他法律及據之作成之具外部效力的規範，例如中央部會制訂之區域計畫、國家公園計畫、水源區土地使用限制計畫，但本文認為這些應景由修法，儘量先經行政爭訟途徑。

6. 憲法所保障之地方自治權

憲法訴訟法第82條立法理由（二）指出：「地方自治團體於受憲法保障前提下，享有自主組織權及對自治事項制定規章並執行之權限。」³⁸「依憲法第十章、第十一章及憲法增修條文第九條第一項之規定，直轄市及省、縣地方制度受明文保障，是本條第一項所稱之地方自治團體，限於直轄市及省所監督之縣（市），而尚不及於鄉（鎮、市）。」

本文認為，所稱「自主組織權及對自治事項制定規章並執行之權限」固然有一定之內涵，但未必完備，而應進一步涵蓋人事、財政等之權限³⁸。就德國法之比較，詳後述。

³⁸ 憲法的地方自治保障規定為：第108條第1項後段（中央立法交由省縣執行之事項）、第110條（縣立法並執行之事項）、第111條（均權原則）係保障地方自治團體之立法權與執行權，以及第118條（直轄市之自治，以法律定之）、第124條（縣設縣議會，縣議會議員由縣民選舉之；屬於縣之立法權，由縣議會行之）、第126條（縣設縣政府，置縣長一人；縣長由縣民選舉之）、第127條（縣長辦理縣自治，並執行中央及省委辦事項）。憲法增修條文第9條除了精省修憲有關者外並沒有變動。其中，權限劃分規定例如「縣立法並執行之事項」，從用詞以觀，係同時涵蓋地方立法與行政機關。

7. 訴之聲明與主張

我國憲法訴訟法第82條第2項規定準用憲政機關提起規範違憲審查之訴，所以聲請書應記載應「受判決事項之聲明」、「法規範違憲之情形及所涉憲法條文或憲法上權利」、「聲請判決之理由及聲請人對本案所持之法律見解」、「關係文件之名稱及件數」等。

8. 鄉鎮市不享有機關爭議權

關於起訴主體，本條的規定為「地方自治團體之立法或行政機關」，但卻在理由欄指出：「地方自治團體於受憲法保障前提下，享有自主組織權及對自治事項制定規章並執行之權限。依憲法第十章、第十一章及憲法增修條文第9條第1項之規定，直轄市及省、縣地方制度受明文保障，是本條第1項所稱之地方自治團體，限於直轄市及省所監督之縣（市），而尚不及於鄉（鎮、市）。」

本文的評論有二。首先，如前所述，機關爭議不宜由地方立法與行政機關提出，已如前述，鄉鎮市地位在縣之下，數目多，爭執案件之全國政治影響性一般較低，所以無必要賦予之。其次，從機關爭議之既然引進而言，固然憲法地方自治保障規定不及於鄉鎮市，但反面言之，憲法也沒有禁止立法者對鄉鎮市採取自治體制，我國地方制度法係採之³⁹，則就鄉鎮市自治機關權限行使所生憲法爭議，從主觀公權利及客觀之釐清憲法地方自治保障意旨以觀，非不可賦權聲請權限爭議憲法裁判，但問題在於憲法沒有鄉鎮市自治保障之規定，若要類推比照縣，則也有一定之不精確性與困難。

39 地方制度法對鄉鎮市有諸多保障，包括自治事項、地方立法權與執行權、地方行政首長與議員各自直接民選產生、各依地制法規享有業務權責，包括業務、人事、組織與財政等面向。

參、地方自治團體之裁判憲法審查

憲法訴訟法第83條第1項規定：「地方自治團體，就下列各款事項，依法定程序用盡審級救濟而受之不利確定終局裁判，認為損害其受憲法所保障之地方自治權者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決：

- 一、自治法規，經監督機關函告無效或函告不予核定。
- 二、其立法機關議決之自治事項，經監督機關函告無效。
- 三、其行政機關辦理之自治事項，經監督機關撤銷、變更、廢止或停止其執行⁴⁰。」

依本條，得起訴之主體為地方自治團體，所主張的事由為「團體權利」之受侵害；其次，限於三種事由；第三，其係針對「終局裁判」所表示的意見，這是爭執的客體（Beschwerdegegenstand）。所以本條所規定者，為「裁判憲法審查」（Urteilsverfassungsbeschwerde），而非「法規範憲法審查」（Rechtssatzverfassungsbeschwerde）。

其理由欄主要指出：1. 地方自治團體既係基於憲法所保障之地方自治權受侵害，類同於人民憲法所保障之基本權受侵害，而得提起行政爭訟，則於其用盡審級救濟途徑，仍受有不利之確定終局裁判之情形下，應許其類同於人民之地位，聲請憲法法庭為裁判憲法審查。2. 本訴訟屬準裁判憲法審查之案件，關於其聲請書之記載事項、受理之方式及裁判主文之諭知等規定，均可援用裁判憲法審查之相關規定⁴¹。

40 其他規定為憲法訴訟法第83條：「前項聲請，應於確定終局裁判送達後六個月之不變期間內為之」（第2項）。「第1項案件，準用第60條、第61條及第62條第1項前段規定」（第3項）。

41 憲法法庭如認地方自治團體之聲請有理由時，準用憲法訴訟法第62條第1項前段規定，應廢棄原確定終局裁判，發回管轄法院；至於其權限爭議之釐清及對於監督機關應如何行使其權限之具體指示，宜於理由內說明，俾使行政法院有

以上顯示，本條儘管說明欄指出「應許其類同於人民之地位，聲請憲法法庭為裁判憲法審查」，但畢竟只開放裁判憲法審查，而與憲法訴訟法第59條人民也得提出「法規範憲法審查」，明顯不同。其次，因準用憲法訴訟法第61條，本訴訟「於具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利所必要者」，憲法法庭始決議受理之⁴²。

第三，本條之起訴主體為地方自治團體，以團體權利受到侵害並窮盡訴訟途徑為要件，而與憲法訴訟法第82條機關爭議不同⁴³。

一、何謂「裁判憲法審查」？以「個人裁判憲法訴願」作為觀察

本條規定地方自治團體之裁判憲法審查，由於新設，得以個人之裁判憲法審查略作初步理解及比較觀察。

所依循。

42 審查庭就承辦大法官分受之聲請案件，得以一致決為不受理之裁定，並應附理由；不能達成一致決之不受理者，由憲法法庭評決受理與否。前項一致決裁定作成後十五日內，有大法官三人以上認應受理者，由憲法法庭評決受理與否；未達三人者，審查庭應速將裁定公告並送達聲請人。

43 2013年版司法院大法官審理案件法修正草案第86條規定「地方自治團體因辦理自治事項於三種類型受上級機關函告無效、撤銷、變更、廢止或停止其執行之個案決定之機關爭議」：「地方自治團體就下列事項，得準用行政訴訟法第4條至第6條規定，提起行政訴訟；於用盡審級救濟程序而受不利確定終局裁判後，認對其受憲法所保障之地方自治有造成損害之虞者，得聲請憲法法庭為機關爭議（！）之判決：一、自治法規或議決之自治事項，經有監督權之各級主管機關函告無效或函告不予核定。二、辦理之自治事項，經有監督權之各級主管機關撤銷、變更、廢止或停止其執行。三、有監督權之各級主管機關，對於自治法規或議決之自治事項，於相當期間內未予核定。第87條第2項規定：地方自治團體依第86條就自治條例或議決之自治事項聲請判決者，應由地方立法機關提出；就自治規則或辦理之自治事項聲請判決者，應由地方行政機關提出。」本文認為：以上究竟涉及機關爭議，或地方自治團體之裁判或法規範之憲法審查，非無疑義。

(一) 源於基本權之拘束力、針對判決、須窮盡訴訟途徑、限於「特別憲法」之違反

憲法訴訟法第59條規定，「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」(第1項)。「前項聲請，應於不利確定終局裁判送達後六個月之不變期間內為之」(第2項)。

以上顯示，其係包含「法規範憲法審查」與「裁判憲法審查」。前者採行既有司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款，後者為新增。理由欄指出：於現行確定終局裁判適用之法規範審查制度下，大法官只進行抽象法規範審查，不具體裁判憲法爭議；現行大法官職司的憲法審查並無法處理各法院裁判在解釋法律及適用法律時，「誤認或忽略了基本權重要意義，或是違反了通常情況下所理解的憲法價值等等司法權行使有違憲疑慮的情形」(按，引號為本文所加)。本項之「法規範」，係指中央及地方之立法與行政機關之立法行為，故包括法律位階之法規範及命令位階之法規範。

問題在於，憲法法院並不是第四審，而是一個憲法明定職掌的機關。憲法法院就終審法院(在我國包括最高法院、最高行政法院、公務員懲戒委員會)的裁判應如何行使審查權，才能守住憲法法院而非第四審法院之界限？這問題我國憲法訴訟法第62條「憲法法庭認人民之聲請有理由者」，並沒有清楚的規定⁴⁴。

(二) 德國法之比較

由於我國個人裁判憲法審查剛剛引進，細緻發展尚有待觀察，所以得略參考德國「個人所提起之憲法訴願」(Individual-

⁴⁴ 至於憲法訴訟法第61條所稱「具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權所必要」係指稱大法官之審查標準，而非違憲審查的範圍。

verfassungsbeschwerde)。依德國基本法第91條第1項第4a款，任何人得主張基本權或類如基本權之權利受到公權力的侵害，而向聯邦憲法法院提起「個人之憲法訴願」。

1. 功能與要件

依德國學界的說明⁴⁵，本制度有兩方面之功能。首先，其為基本權所保障之個人權益保障體系的最終點，也是最高點；個人憲法訴願係一特別的，非通常性的權利保障機制（ein ausserordentlicher Rechtsbefehl），其為「從屬性的」（nur subsidiaer），作為基本權為特別保障之最終手段（als letztes Mittel zum speziellen Schutz der Grundrechte）。其次，其也有客觀面之功能：憲法具最高位階，在制度設計上，吾人應促使憲法條文能夠與時俱進發生效力，並持續發展；若重大的憲法問題沒有辦法經由機關爭議或規範違憲審查加以釐清，則個人的憲法訴願尤其是一個可以用得上的機制。

在要件上，儘管從條文以觀，上開條文並未限定針對法院的判決，理論上得涵蓋法律、法規命令、自治條例、統治行為、行政處分及其他類型之行政措施，例如行政機關間之協議、赦免行為、各層級法院之裁判（但不包括聯邦憲法法院本身者），但因要件中有直接受侵害（Unmittelbare Betroffenheit）及須窮盡救濟途徑，所以本訴訟的客體通常為終審法院的判決及於若干情形下判決所依據的法律⁴⁶。其次，憲法訴願者必須本身、現在、直接（selbst, gegenwärtig, unmittelbar）受到系爭措施干預以致於基本權受到影響⁴⁷。

人民的憲法訴願，依聯邦憲法法院法第93a條第1項，須經聯邦

45 Maurer (Fn. 21), § 20 Rn. 119-121.

46 Maurer (Fn. 21), § 20 Rn. 126.

47 Maurer (Fn. 21), § 20 Rn. 128.

憲法法院決定「受理」，要件為，系爭的憲法訴願「具有憲法上的原則意義」(Grundsätzliche Verfassungsrechtliche Bedeutung)，或是憲法訴願的受理係「為了貫徹基本權」。前者係指，系爭憲法訴願所提出的憲法問題不能直接從基本法得到答案，或尚未經憲法法院的裁判所釐清，或即使釐清但因為情勢變遷而有必要作成一個新的釐清。後者係指，若憲法法院拒絕受理，則憲法訴願人將遭受特別嚴重之不利利益⁴⁸。

本訴訟須窮盡訴訟途徑始得提起，但聯邦憲法法院法第90條第2項第2句規定例外，亦即，當其具有一般重要性(von Allgemeine Bedeutung)或若不立即審理憲法訴願人將蒙受一個嚴重而且難以對抗的不利益(ein schwerer und unabwendbarer Nachteil)。就地方自治團體所提起的憲法訴願，聯邦憲法法院第91條並沒有類似的規定，而有待解釋，詳後述。

2. 聯邦憲法法院的審查權責與範圍

就裁判所適用的「法規範」是否違憲之審查範圍(Prüfungsumfang)，一如一般之規範違憲審查般，審查的客體及標準可謂係相當確定，或至少得確定。就「裁判」憲法訴願而言，聯邦憲法法院所審查者，為系爭判決的法律解釋見解是否合憲，而非是否合於實定法律條文。換言之，於此係區分「法律條文之單純解釋」與「法律條文之憲法有關的解釋」。

首先，為所謂「赫克公式」(Hecksche Formel)。個人裁判憲法訴願的構想為，專業法院於適用法律進行判決時也係為行使公權力之主體，也受到基本權的限制⁴⁹。赫克公式是1964年6月10日聯邦

48 Jarass/Pieroth (Fn. 16), Art. 93 Rn. 46-47.

49 Maurer (Fn. 21), § 20 Rn. 137; Herbert Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Lfg. 53 Februar 2018, § 90 Rn. 279.

憲法法院在一個專利權有關的決議中所提出。其指出，專業法院於解釋與適用實定法時，於解釋其中之概括條款（*Generalklauseln*）時，必須能夠注意到基本法所設下之價值標準。若法院對這個標準有所疏忽，則其作為公權力主體係違反其所應受到拘束之基本權，其判決必須經由憲法訴願而被聯邦憲法法院所撤銷⁵⁰。依照如上公式，聯邦憲法法院只有於如下情形始享有審查權（*eine Prüfungskompetenz*），亦即，當終審法院在解釋實定法時，出現一個植基於對於基本權意義之原則性不正確之見解，尤其有關基本權的保障範圍及其實質上的意義，而且該錯誤具有一定之比重；聯邦憲法法院於此強調個人憲法訴願係作為客觀憲法之特別的權利保護機制（*als spezifisches Rechtsschutzmittel des objektiven Verfassungsrechts*），從而須有如上要件⁵¹。以上係由當時憲法法院法官赫克（*Karl Alexander Wilhelm Heck*）所提出，並被援用至今。這個公式又稱為「特別的憲法」。依之，就終審法院的程序如何進行、對要件事實之如何確定與評價、對於實定法律之解釋及於該個案之適用，凡此為終審法院的權責，聯邦憲法法院不得審查；當系爭判決意見違反「特別的憲法」時（*Verletzung von spezifischem Verfassungsrecht*），聯邦憲法法院始得介入。所謂系爭判決意見違反特別憲法，於系爭的判決意見只是客觀上罹於有瑕疵時並不該當，毋寧，必須是系爭法律見解瑕疵係出於對基本權之未予遵守；換言之，聯邦憲法法院並不審查系爭判決見解依實定法規定是否正確，蓋這是終審法院的權責；聯邦憲法法院只審查，是否系爭判決之法律解釋上瑕疵係屬於明顯，而且基於一個對基本權之原則性不

⁵⁰ *Bethge* (Fn. 49), § 90 Rn. 316.

⁵¹ 德國這方面的文獻很多，請參見 *Corinne Rüchardt*, „Strafbare Satire?“ Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Urteilsverfassungsbeschwerde, JA 2017, S. 514 (519); *Rüdiger Zuck*, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 5. Aufl., 2017, Rn. 579 ff.; *Klaus Schlaich/Stefan Koriath*, Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 11. Aufl., 2018, Rn. 280 ff.（筆者使用為臺大Beck-online法學資料庫；最後瀏覽日：2019年5月15日）。

正確見解，尤其有關基本權的保障範圍及實質上意義。換言之，聯邦憲法法院只有在如下情形始得作出更正決定，亦即當專業法院的法律解釋結果係超越基本法所設定的範圍。換言之，本處所涉及者，為憲法條文對於實定法之實質上的射程距離及照耀效力（*die materielle Reichweite und Ausstrahlungswirkung des Verfassungsrechts in das „einfache“ Recht*）⁵²。以上顯示，所謂赫克公式，亦即所謂特別憲法之公式，其並不是指憲法中的某一個個別章節或個別之具一定特殊性質的條文之受到系爭判決的見解所違反，而是指必須有「實質憲法上之特別原因」（*Spezifische Gründe des materiellen Verfassungsrechts*）⁵³。

以上，可稱為聯邦憲法法院的審查範圍，但這在一般的訴訟而言係屬於訴之有無理由問題，但在個人憲法訴願之審理上，這問題必須被拉到前置階段，蓋這涉及聯邦憲法法院審理的權責⁵⁴。

除了赫克公式之外，尚有所謂「舒曼公式」（*Schumannsche Formel*），源於舒曼（*Ekkehard Schumann*）1963年所發表的文章。其命題為：終審法院對法律的錯誤解釋於如下情形對聯邦憲法法院係無關重要的，亦即，當實定法律之立法者在對系爭素材進行規定時，即使於未經基本權有關的指責情形下，也會達到一如終審法院法官判決所採之見解；換言之，所謂「特別的憲法」於如下情形係受到違反，當系爭裁判係採行一個立法者不得制定的規範而判決意見竟然採行之（*Eine Rechtsfolge, die der einfache Gesetzgeber nicht als Norm hätte erlassen dürfen*）⁵⁵。這公式固然指出一個標準，但缺點在於，實定法律之立法者究竟會如何作出立法決定，對憲法訴願當事人而言，其必須花相當大的時間與力氣去進行整理，而事實

⁵² *Schlaich/Korioth* (Fn. 51), Rn. 280-282.

⁵³ *Schlaich/Korioth* (Fn. 51), Rn. 282.

⁵⁴ *Schlaich/Korioth* (Fn. 51), Rn. 281.

⁵⁵ *Zuck* (Fn. 51), Rn. 580, 601a; *Rüchardt* (Fn. 51), S. 519.

上所整理出來的也難謂絕對確定之診斷或論斷⁵⁶。

不論是赫克公式或舒曼公式，學者指出，於一定程度為「內容空洞的公式」(Leerformel)，但另一方面無可諱言，其畢竟是一個「簡短的公式」(Kurzformel)，從而有寬廣的適用可能性，關鍵在於聯邦憲法法院與專業法院之間的審查權劃分問題；這進一步而言也是聯邦憲法法院與立法者之功能與權限劃分的問題⁵⁷。

經由教科書對判決之整理與詮釋，赫克公式於當今得包含：

1. 法官於解釋適用系爭實定法律時並沒有理解到基本權的關聯性。
2. 法官儘管已經注意到基本權的關聯性，但於解釋時犯有原則性的錯誤，亦即發生一個基本權之錯誤評價 (Fehleinschaetzung)。
3. 重點在於，專業法院法官的法律解釋結論係違反當事人所主張的基本權；換言之，重要的是判決的結論本身，而非說理的過程 (Grundrechtsverstoß durch das Entscheidungsergebnis)。
4. 法院的判決係客觀上難以支持，從而係具有恣意性 (objektiv unhaltbare und deshalb willkürliche Gerichtsentscheidungen)。
5. 法官於審判中以相關法律整體沒有規定為由，而進行「法官之法的續造」(richterliche Rechtsfortbildung)——這是超越法律漏洞填補之層次，而其逾越憲法的界線。
6. 除了以上之外，聯邦憲法法院在判決中曾提出如下附帶性的觀點：其就此的審查權責並不是僵化的，不能於每個案件都作相同的劃定，而須保持有一定的空間，來衡量個案的特殊情形；迄今為止所提出的標準從而並不是一個僵化的界限，而是具有一定的流動性 (fließende Grenze)；若個案中基本權的干預愈是嚴重 (Intensität des Grundrechtseingriffs)，則越能正當化憲法法院之介入⁵⁸。

⁵⁶ Vgl. Zuck (Fn. 51), Rn. 601a.

⁵⁷ Vgl. Zuck (Fn. 51), Rn. 580.

⁵⁸ 以上由判決發展出來的細緻命題整理，參見 Schlaich/Korioth (Fn. 51), Rn. 294-310. 就文獻上對於以上命題之批評性意見，Schlaich/Korioth, aaO., Rn. 310 ff.

除了以上對於法院判決意見之違憲審查之外，聯邦憲法法院在判決中也針對專業法院判決的程序——主要指有無遵循基本法訴訟權保障及聽審規定。除此之外，裁判憲法訴願也得針對判決所適用的法律本身（Kontrolle des zugrunde liegenden Gesetzes）⁵⁹。

二、檢討

於比較觀察之後，得針對本條之立法得失與主要釋義問題，進行討論。

（一）地方自治團體不得提起「法規範憲法審查」，是有不足

本條所開放之中央對地方辦理自治事項之監督「屬於法律層次之各種具體監督行為，涉及監督行為的合法性，與憲法所直接規定之自治權限的內涵上有不同層次的差異」，現亦有行政爭訟的救濟途徑可以採行⁶⁰。相關監督處置於判決確定之後，得有裁判或法規範憲法審查之問題。本文認為，地方自治團體不得針對確定裁判所依據的法規範提起違憲審查，是有嚴重不足，法規範之憲法審查才是直接、有效之地方自治憲法保障機制，德國法採之。

憲法訴訟法第59條規定，「人民」就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判。從文字以觀，起訴之主體為「人民」，解釋上固然得包括「私法人」，而不包括地方自治團體；地方自治團體憲法上定位為「制度保障」，非自然人，不享有基本權，從而不享有個人之規範或裁判憲法審查⁶¹。

⁵⁹ Vgl. *Schlaich/Korioth* (Fn. 51), Rn. 321-327.

⁶⁰ 吳信華（註37），頁99。

⁶¹ 吳信華也認為，地方自治團體不可能享有旨在保護人民對抗國家不法侵害之基本權，所以憲法訴訟法當中的個人裁判憲法審查之起訴主體，不包括地方自治團體。參見吳信華（註37），頁97-98。

（二）憲法法庭受理之要件與審查之範圍（權責）

因準用憲法訴訟法第61條，並非條文所列三種對於地方自治之監督處置之裁判見解均進入實質審查，而是限於「具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利必要者」。其次，即使受理，若參照德國法「赫克公式」，則憲法法院只於下述情形始得介入，亦即，判決之法律見解犯有原則性的錯誤，而且源於對基本權之原則性不正確的見解，尤其有關基本權的保障範圍及實質上意義。以上有關基本權字眼，於此應指地方自治團體基於制度保障地位所擁有之「高權」。

（三）本條採裁判憲法審查，是否妥當？

於此理論上得有二說，本文採後者。

第一說採批判立場：首先，地方自治團體只能針對自治監督之處置，而三種事由之法律要件規定可謂相對清楚，行政法院所得進行的「法律解釋空間」不是很大，裁判見解違法與違憲的機率相對較低；若有違憲可能，則主要為法律。此外，復有憲法法庭決議受理之要件及進行違憲宣告的要件（參見赫克公式），構成裁判憲法審查的勝訴門檻或障礙。德國法上「個人裁判憲法訴願」所以能有發展的空間以及主要的適用案型，為管制基本權的法律之構成要件具有抽象性，而基本權的憲法條文用詞抽象，所以留下相當大的與時俱進及針對不同案型而細緻區分與發展的「憲法解釋空間」——我國一個得觀察的經典案例，為司法院釋字第407號解釋有關「猥褻」一詞的界定。憲法訴訟法第83條所規定的三個條文難謂過於抽象，而憲法有關地方自治團體保障之規定難為如基本權條文般之抽象與開放，所以難使用裁判憲法審查。第三，於行政訴訟中，高等行政法院與最高行政法院得以「系爭法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法，且於該案件之裁判結果有直接影響」，聲請憲法法庭為宣告違憲之判決；地方自治團體非無合宜的權利保障機

制，無須開放裁判憲法審查（參見後述德國法「地方自治團體之憲法訴願」之說明）。

第二說認為，本條採裁判憲法審查也具有意義：1. 如德國法比較所顯示，地方自治團體憲法訴願的爭訟客體不包括法院的裁判將或多或少產生權利保護上的漏洞，但地方自治團體得經由行政爭訟主張權利保護或經由法院提起具體之規範違憲審查。2. 我國憲法地方自治保障規定多不精確而留下與時俱進發展的可能。舉例言之：憲法第107條至第110條有關中央與地方的權限劃分規定，款目多有重疊，抽象的標準也難為已經確立（例如，德國邦法多以「危險防禦」作為區分標準）；儘管憲法第111條補充地提出「均權原則」，但畢竟為「內容空洞的公式」；我國憲法上中央對地方自治團體的監督規定極為有限，對於地方財政自主保障、組織權、人事權、都市計畫高權、地方自治條例得否制訂罰則及法律保留等，憲法的規定也不甚清楚。在以上意義內，與人民基本權的條款般，因抽象或精確，而留下相當的憲法解釋空間與必要。3. 德國法也承認，於特定之（因法律抽象或不精確）需要由判決加以形成之特別領域，地方自治團體之裁判憲法訴願仍有積極意義⁶²。

62 「德國地方自治團體之憲法訴願」的爭執客體，為聯邦或邦之法律，或其他具外部效力性之規範，但不包括法院判決（精確言之，為法院於判決中對實定法律所表示的解釋意見）。這個規定的妥當性或得突破之處，可由聯邦憲法法院2016年一件不受理決議的理由，窺見一斑（Vgl. BVerfG, Beschl. v. 22.8.2016, NVwZ 2016, S. 1630）。本件的案件事實約為，某一地方自治團體擁有轄區內公共道路的路權，而與A有限公司訂立契約，由該鄉鎮市提供路權予該業者，使鋪設及經營有關的暖氣的管線，以照顧轄區內居民的需要。於契約屆期之前，該鄉鎮市出於另外的考量，而與B有限公司締約，該鄉鎮市擁有B公司60%股權，其他參與者為40%。A公司乃以系爭鄉鎮市的決定違反「營業競爭管理法」（GWB）濫用市場支配地位之規定，而向聯邦卡特爾署起訴。該鄉鎮市遭不利益的處置並且一路敗訴確定，乃提起地方自治團體之憲法訴願，請求確認以下三個禁止之判決意見違反憲法之地方自治保障規定而無效：禁止由鄉鎮市於未先行經招標程序便可直接接收轄區上的能源配送網路，以及前述情形下招標時禁止由地方自治團體所參與的公營事業優先得標，以及有關在地方能源配送網路的經營者選擇上之禁止衡量地方之特殊利益。這些並不是「營業競爭管理法」的條文規定，而是聯邦法院（BGH）於先前兩個判決中所持見解。聯邦憲

（四）限於地方辦理自治事項之三種監督處置，不無窄化

地方自治團體之裁判憲法審查只能針對中央對地方自治行使監督權之三種情形，對中央自行制訂之法規命令或其他具外部效力性的規範——例如主管部會所制頒的區域計畫、國家公園保護計畫、水源區計畫……，或中央部會依法律規定對個別重大開發案所為的

法法院認為本件憲法訴願不合法，決議不受理，理由在於，地方自治團體的憲法訴願係以聯邦或邦之法律或其他具有外部效力性的規範違憲，法院的判決不屬之，儘管法官於個案中對法律的解釋適用，基本上也是有一定的造法層次（這係因為法條的抽象性及每個案件事實的特殊性），文獻上也非無主張法官的判決意見甚至習慣法，也得作為地方自治團體憲法訴願的合法客體，但無論如何，若一般性地承認法院的判決具有法規性質，則地方自治團體憲法訴願將遭扭轉，成為涵蓋判決憲法訴願的情形，而這與制憲者及立法者的意旨明顯抵觸。所以最多而言，若真要承認判決憲法訴願，也僅能限於「形成一個特定法領域之法院見解」（*Richterrecht, das ein bestimmtes Rechtsgebiet prägt*）——這是本論文所關懷者。其次，地方自治團體憲法訴願不得針對法院判決意見，並不致於出現權利救濟漏洞之問題，理由之一為，各專業法院於判決中於法律條文留有解釋空間時，便須針對基本法有關聯邦於經濟法領域及營業競爭管理法領域之立法權，及邦之地方自治立法權之間，以及基本法第28條對鄉鎮市的保障，加以衡量，所以專業法院於解釋適用本件有關的法律時，就已經能夠衡量地方自治團體以自我責任完成決定的必要與可能；其次，若專業法院於適用前述法律時認為有違憲情形，則得暫停審判而向憲法法院提起具體的規範違憲審查。1994年4月19日北萊茵—西伐利亞邦憲法法院判決，提供若干的說明。本件提起憲法訴願者為邦內的某個縣，針對該邦內政部長於1992年3月27號對邦之縣市與鄉鎮市所作成的函釋，依之，此等有義務提供所屬公務人員「特殊的補助」（*Sonderzuschlägen*）。該縣認為系爭函釋得為地方自治團體之憲法訴願標的，認為其侵害憲法上的自治權。邦憲法法院於判決中指出，該邦憲法法院法准許地方自治團體針對法律、法規命令及其他具外部效力的規範，包括習慣法及依該邦國土暨區域計畫法所完成之區域計畫，但並不包括本案的函釋。理由為，地方自治團體得針對該函釋，甚至後續的上級監督機關所作指令或處置，向行政法院起訴，從而已經獲得足夠的權利保障（*ausreichender Rechtsschutz*），不需有地方自治團體之憲法訴願；即使地方自治團體對該函釋不得直接提起行政爭訟，而須等到主管機關作成後續之個案監督處置，但這也是地方自治團體的權利保障，若有例外，例如若等到個案監督處置則不免過於遲緩，蓋縣政府公務人員可能依據該函而紛紛主張給付請求權，而縣政府立即支付又很可能有難以回復之損害，則其也得依行政法院法提起「預防性的確認訴訟」以作為救濟。Vgl. Ministerialerlass Kein zulässiger Gegenstand kommunaler Verfassungsbeschwerde, NRW-VerfGH, Urteil vom 19.04.1994, NVwZ-RR 1995, S. 101; vgl. *Thomas Starke*, Grundfälle zur Kommunalverfassungsbeschwerde, JuS 2008, S. 319 (321).

環評審查之「通過」，或目的事業主管機關最終所作成的准許開發之決定，地方自治團體即使團體權利受侵害，於敗訴確定後也無權提出聲請。

（五）關於訴權

地方自治團體的裁判憲法審查須以團體權利受侵害，不得以個別機關或個別類型居民的權利受侵害為由；這必須是憲法上的權利；這權利旨在保障地方自治團體；地方自治團體於訴狀中須充分指陳受波及之憲法權利規定，其自身有如何之權利行使情形，受到何種的侵害，侵害的嚴重性等，並最好能有一定之數據支撐。

三、比較法之觀察：德國法採「地方自治團體之憲法訴願」，原則上須窮盡訴訟途徑，性質上為規範違憲審查，而非裁判憲法訴願

地方自治團體基於憲法之制度保障，有權針對團體權益受侵害案件提起行政爭訟，以及於敗訴確定後提起地方自治之憲法訴訟，以下詳為說明。

（一）基本法與邦憲法有關地方自治團體地位之規定與解釋

德國基本法第28條第1項第一句規定「鄉鎮市必須被擔保如下的權利，亦即就地方共同體所有事項於法律框架內以自我責任完成決定」；就縣而言，同項第二句規定，鄉鎮市聯合體也於法律所規定的任務範圍內，依法律的標準而享有自治權。不論就鄉鎮市或縣，法條均使用「權利」(Das Recht)；對鄉鎮市而言其規定「必須」(Müssen)被擔保享有權利。以上顯示，基本法制定者對於賦予權利，有相當清楚的決定。除此之外，基本法第28條係規定於「聯邦與邦的關係」節章，而不是於基本權中。基本法的規定為

「最低保障」(Mindestgarantie)，邦憲法得有進一步的規定⁶³。

根據如上規定，地方自治團體一方面為國家組織(法)的一環，國家對地方自治的內涵得有一定之形成權(*gestalten*)；地方自治團體為國家組織法上的一環，制度保障是一種於國家內的職掌劃分(*Verteilung von Kompetenzen*)。但另一方面，地方自治團體卻同時被賦予自治權，國家於干預時，必須予以尊重；國家所為對地方自治團體的干預措施必須出於正當化事由(*Rechtfertigung aller staatlichen Massnahmen*)，而且不得過當。這稱為「制度保障」，指其有別於「人民基本權之保障」，蓋地方自治團體並不是自然人，從人民基本權的發展歷史及如上地方自治團體保障於基本法及邦憲法章節而言，其並非自然人。

德國法經由判決與學說，地方自治之制度保障包含如下面向：首先，其為「制度性之法律主體之保障」(*institutionelle Rechtssubjektsgarantie*)，其係作為國家(指聯邦與邦，尤其後者)之下行政組織的一環，必須存在，而不得根本地遭到刪除而成為沒有這個層級之存在⁶⁴。其次，其係「一個客觀法上的而且也是以主觀公權利方式加以保障之法制度」(*objektiv-rechtliche und als subjektives Recht garantierte Rechtsinstitutionsgarantie*)，二者得統稱為「法制度之保障」。客觀法上的保障面向係指地方自治團體被保障擁有一定的任務組成；主觀法上的保障得展現於，地方自治團體享有「地方自治團體之憲法訴願」權能及依行政法院法有關規定，針對國家影響地方自治權利的措施，提起行政爭訟之權能(*Klagebefugnis*)。反之，地方自治團體僅相對獲得保障的，為個別鄉鎮市之存續。於客觀法暨主觀之法律地位保障之下，可分為有關

63 *Martin Burgi*, Kommunalrecht, 4. Aufl., 2012, § 6 Rn. 1 f.

64 Vgl. *Alfons Gern*, Deutsches Kommunalrecht, 3 Aufl., 2003, Rn. 49 f.; *Burgi* (Fn. 63), § 6, Rn. 4 ff.

「任務之保障」(指自治事項)及有關地方以自我責任方式而為決定之保障，後者包括：如何辦理有關任務之保障，有關組織高權、人事高權、財政高權、計畫高權、自治規章制定高權、合作高權等；但以上的保障並非絕對，而是如德國基本法第28條第2項前段所稱，係在法律的框架內(im Rahmen der Gesetze)⁶⁵。地方自治團體並不享有「個人之憲法訴願」(指於敗訴確定後以基本權受侵害為由，針對終局判決所適用的法規範或判決本身，向聯邦憲法法院提起)，而是自成一格之「地方自治團體之憲法訴願」(Kommunalverfassungsbeschwerde)，而於德國基本法第93條第1項4b款有特別的規定。

總而言之，德國法從基本法第28條權利的規定用詞、其他法條、邦憲法的規定，以及相關判決與學說的發展，均肯認地方自治團體所享有的制度保障地位，係包含一種主觀公權利的意涵，針對聯邦與邦(主要為後者)，並得依法律規定而以作為、不作為或忍受之請求權、行政程序上的參與權，或行政爭訟權，而為展現⁶⁶。

地方自治團體的憲法訴願(kommunale Verfassungsbeschwerde)規定於德國基本法第93條第1項第4b款：鄉鎮市或縣就基本法第28條所保障的自治權，於遭受法律或其他規範的侵害，得提起憲法訴願。其非「聯邦—邦間之權限爭議」，也非「自然人之憲法訴願」(Individualverfassungsbeschwerde)，而為「制度保障說」之一項內涵⁶⁷。

⁶⁵ 有關地方自治團體的任務保障以及各種高權，參見Burgi (Fn. 63), § 6 Rn. 22-33; Gern (Fn. 64), Rn. 56-78.

⁶⁶ Burgi (Fn. 63), § 6 Rn. 20.

⁶⁷ Vgl. Axel (Fn. 16), Art. 93 Rn. 204 f.

（二）性質與要件

1. 規範違憲審查、主觀訴訟

本訴訟由邦之地方自治團體所提起，以邦之法律違反邦憲法所保障之地方自治規定為理由。本訴訟屬於「規範違憲審查」，若干邦直接使用「地方自治團體之規範審查」（kommunalrechtliche Normenkontrolle; kommunale Normenkontrolle），與「判決憲法訴願」（Urteilsverfassungsbeschwerde）不同⁶⁸。德國法採行主觀訴訟，地方自治團體須以憲法所規定之地方自治保障規定受侵害為要件。

德國法採主觀訴訟，並原則上適用人民憲法訴願之規定（見聯邦憲法法院法第90條第2項、第3項，第91至95條）⁶⁹。地方自治團體係以團體之地位起訴，以憲法保障之地位（權利）受到侵害為理由，起訴時須符合訴權要件（Beschwerdebefugnis）。

2. 起訴之主體

有權提起者為鄉鎮市、縣市，不包括其他類型之自治體，後者如地方政府就特定事項經由法律規定成立之「單元的目的事業公法人」，或於都會區針對多重業務而依法成立之具地方政府間合作功能之「多元的目的事業公法人」。大城市內部之區（Bezirk）也不享有之。

3. 爭訟之客體

地方自治團體憲法訴願的爭訟客體（Streitgegenstand），具重要性，應妥為討論。

⁶⁸ Vgl. Max-Emanuel Geis, Kommunalrecht, 3. Aufl., 2014, § 26 Rn. 11 f.; Gern (Fn. 64), Rn. 84 f.

⁶⁹ Vgl. etwa Axel (Fn. 16), Rn. 204-206.

(1) 法律、法規命令或其他具外部效力之規範

依德國基本法第93條第1項第4b款規定為「法律」(ein Gesetz)，包含聯邦與邦之法律，但經由聯邦憲法法院判決之詮釋，「法律」一詞在此不再限於形式意義之法律，目前已經放寬到邦或聯邦之法規命令、國土計畫、區域計畫、地區發展計畫、相鄰鄉鎮市之都市計畫（性質上為自治條例；Satzung）、具拘束力之專業計畫等。各邦憲法的規定不一，有的仍然維持只限於邦法律違反邦憲法上地方自治保障始得提起，有的邦則較為放寬。例如下薩克森邦憲法訴願客體限於邦法律，而不包括其下之法規命令。北萊因－西發里亞邦的規定為「任何種類的邦法」(Landesrecht jeder Art)，只要地方自治團體沒有支配權限即可，所以邦政府所制訂之「地區發展計畫」(Gebietsentwicklungsplan)也得成為爭訟的客體；若蘭－發芝邦係包括任何其他種類的公權力決定；薩蘭邦也是採廣義⁷⁰。法院的裁判或行政機關的個案決定不屬之⁷¹。

(2) 不包括上級機關對地方自治團體所為的監督處置，因已有行政爭訟機制及具體之規範違憲審查

地方自治團體憲法訴願的客體，也不包括上級機關對地方自治團體所為的監督處置——我國憲法訴訟法正好採之。德國文獻指出，儘管這或多或少將產生一個權利保護上的漏洞，但這畢竟是制憲者的一個明白決定，而且地方自治團體得經由行政爭訟主張權利保護⁷²。

(3) 得否針對聯邦或邦之立法不作為？

地方自治團體之憲法訴願得否針對聯邦或邦之「立法不作

70 Vgl. Gern (Fn. 64), Rn. 843 ff.

71 Vgl. Axel (Fn. 16), Art. 93 Rn. 207.

72 Vgl. Axel (Fn. 16), Art. 93 Rn. 207; Starke (Fn. 62), S. 321.

為」？文獻指出，這問題聯邦憲法法院並沒有作成裁判；於此應區分為立法者之「完全不為行為」（也稱為「真正不作為」），不得被起訴爭執，另外一種則是「法律有規定，但並不充分」（*unzureichende gesetzliche Regelung*，又稱為「非真正之不作為」），亦即聯邦或邦的立法者已經制定一個法律，但該法律的內容並未完整，亦即未能充分符合基本法第28條第2項或邦憲法之地方自治保障規定，而這正是地方自治團體的起訴主張，則此時這種部分的不作為，在評價上係等同於立法者已經積極作出決定，從而地方自治團體之憲法訴願屬於合法提起，這尤其見諸邦「財政收支劃分法」（*Finanzausgleichsgesetz*）之爭訟⁷³。

4. 關於訴權

就「訴權」（*Klagebefugnis*），以行政訴訟法之規定與理論而言，分為三個部分：首先，必須有「權利」之存在（*Vorliegen eines Rechts*）；其次，該權利必須是歸屬於起訴者（*Zuordnung zum Kläger*）；第三，當事人的權利有受侵害之可能（*Möglichkeit der Rechtsverletzung*）⁷⁴。就最後一項，起訴者必須「充分地、證實地提出事實（*hinreichend substantiiert Tatsachen vortragen*）」，從中可以看出系爭處置或規定有可能侵害原告之權利或法律上所保護之利益，亦即，須達到「充分之可信性」（*eine hinreichende Plausibilität*），但不必到達有理由而能勝訴程度，蓋這是訴有無理由之問題⁷⁵。

依通說，地方自治團體起訴時必須主張，其係「自己」、「現今」且「直接」受到不利益（*selbst, gegenwärtig und unmittelbar*

⁷³ *Starke* (Fn. 62), S. 321; *Axel* (Fn. 16), Art. 93 Rn. 206 f.

⁷⁴ *Starke* (Fn. 62), S. 321; *Axel* (Fn. 16), Art. 93 Rn. 206 f.

⁷⁵ *Friedhelm Hufen*, *Verwaltungsprozeßrecht*, 9. Aufl., 2013, § 14 Rn. 108.

betroffen)⁷⁶：所謂「直接」，聯邦憲法法院採較為寬鬆的解釋 (großzügig)；若干預尚待經由法律以下位階之規範得加以具體化時，則尚難謂已經該當。所謂「現今」，係指聲請人因系爭法律而已經或現今還受到侵害，例如系爭法律條文將於未來某一時點失去效力，或已經失去效力但對聲請人而言當前仍具有現實意義 (aktuell)，或總是還需要對其處理，或聲請人有其他之確認其違憲之正當利益。所謂「直接」(unmittelbar)，在解釋上一般係採寬鬆之解釋，亦即，只有當法律尚須經由下位規範具體化時，始可謂不該當；地方自治團體無須總是要等到系爭法律經行政機關的個案行為轉換，始能經由行政訴訟途徑而為主張⁷⁷。舉例言之，若邦原先制定「邦之聯邦社會救助法施行法」，規定縣為邦之承辦社會救助主體，但縣得制定自治條例，而將本任務交由所屬之鄉鎮市，而由縣負擔所有的費用支出，但後來邦修改之，改為鄉鎮市須承擔50%支出，則因系爭修正後之法律尚須經縣自治條例，始得對於個別鄉鎮市產生不利益，所以鄉鎮市尚不能以憲法所保障之自治權遭侵害為由而直接起訴⁷⁸。

5. 須否「窮盡訴訟途徑」？

就憲法法院的管轄事項而言，公法學上一般有所謂「憲法訴訟之從屬性原則」，亦即公法上的爭議案件原則上應先經行政法院，這最明顯表現於「個人之憲法訴願」(Individualverfassungsbeschwerde)，規定於聯邦憲法法院法第90條第2項第一句。但該項第二句也同時規定，聯邦憲法法院得例外立即受理，設若該憲法訴願係「具一般意義 (von allgemeiner Bedeutung)」，或若不如此則憲

⁷⁶ *Starke* (Fn. 62), S. 321.

⁷⁷ *Axel* (Fn. 16), Art. 93 Rn. 208.

⁷⁸ *Starke* (Fn. 62), S. 321; *Benno Kaplonek*, Die Normenkontrolle auf kommunalen Antrag vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, LKV 2005, S. 526 (527); VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 10.12.2002, DÖV 2003, S. 414 (414 f.).

法訴願將遭受一個嚴重且難以回復的損害」。但就地方自治團體之憲法訴願則基本法第28條第2項及邦憲法沒有規定，聯邦憲法法院法（Bundesverfassungsgerichtsgesetz）第91條亦然。

文獻上有從減輕憲法法院負荷的角度，指出地方自治團體之憲法訴願，相較於行政訴訟上之行政救濟而言，係具有從屬性的地位⁷⁹。也有從法律規定著手者，例如巴伐利亞邦憲法法院法第51條規定，若就憲法訴願存有訴訟途徑，則於提起憲法訴願應證明已經窮盡訴訟途徑，行政法院法第47條已經引進對具外部效力的法律位階以下的「規範審查」（Normenkontrolle），以高等行政法院作為第一審管轄；至於哪些領域之「具外部效力的法規範」得由人民或公法人起訴，則由邦於邦行政法院法施行法及專業法律中規定⁸⁰。

但也有不同意見⁸¹：憲法訴願客體通常為「法律」，因只有憲法法院始享有違憲審查權，這才是真的問題所在。地方自治團體的憲法訴願自始便被構想成一種規範的違憲審查，而與個人之裁判憲法訴願於例外始提起規範違憲審查，有所不同。此外，地方自治團體憲法訴願有起訴期間限制，若須窮盡訴訟途徑，則有可能無法於期間內提出。

學者Matthias Dombert指出，本問題難謂已獲最終解決⁸²。首先，於解釋上，一個妥善的觀察方法，為略作「個人憲法訴願」之制度觀察比較。就之，依聯邦憲法法院法第90條第2項，若存有救濟途徑，則當事人應先窮盡訴訟途徑後始得提起，但聯邦憲法於如下例外情形得立即受理，亦即，當憲法訴願具有一般的意義（von allgemeiner Bedeutung），或「若窮盡訴訟途徑將發生嚴重且難以回

⁷⁹ Vgl. etwa *Starke* (Fn. 62), S. 322.

⁸⁰ Vgl. *Starke* (Fn. 62), S. 322; *Bethge* (Fn. 36), § 91 Rn. 47 ff.

⁸¹ *Bethge* (Fn. 36), § 91 Rn. 50 f.

⁸² *Dombert* (Fn. 35), S. 349.

復之不利益」，或地方自治團體所提的憲法訴願案依案情係涵蓋相當廣的射程距離（*Tragweite der Entscheidung*），亦即，系爭的憲法訴願得擴張適用於許多的地方自治團體，則於此吾人應原則性肯認此爭議具有一般性意義，這尤其適用於針對邦財政收支劃分法規定之案件；若於此等法律，地方自治團體尚須等待到邦政府依據該法律作成有關的補助款分配標準，甚至等到相關行政處分作成，則地方自治團體的權益將難期待被有效保護。也有學者指出⁸³，於建立地方自治團體憲法訴願的過程中，係以對聯邦或邦法律之違憲作為設想的客體，而就之並沒有其他的訴訟途徑可供當事人進行，所以整體而言，地方自治團體之憲法訴願與個人不同，無須以窮盡訴訟途徑作為起訴要件；但為減輕聯邦或邦憲法法院負荷，於存有其他訴訟途徑時，地方自治團體應先窮盡之。

聯邦憲法法院於判決指出，若有屬於行政法院層級之訴訟管道或機會存在，則當事人應先向行政法院起訴並窮盡訴訟途徑⁸⁴。約言之，地方自治團體的憲法訴願客體，得為聯邦或邦的法律，或其下位具有外部拘束力的規範，例如法規命令、具有外部拘束力之計畫或方案，就此等，行政法院法第47條第1項第2款開放地方自治團體直接向高等行政法院提起規範審查，並授權各邦於「邦行政法院法施行法」或專業法律規定引進之項目；聯邦層級的法規命令，儘管並非行政法院法第47條所規定，但通說認為，仍得由當事人依行政法院法第43條，向行政法院提起確認訴訟⁸⁵。

6. 須符合「權利保護必要」

儘管德國基本法第93條第1項第4b款並未明文，但通說認為，地方自治團體之憲法訴願必須滿足「權利保護之必要」

⁸³ Thorsten Ingo Schmidt, Die kommunalverfassungsbeschwerde, JA 2008, S. 763 (769).

⁸⁴ Starke (Fn. 62), S. 322.

⁸⁵ Starke (Fn. 62), S. 322.

(Rechtsschutzbedürfnis)，為法律沒有明文之實體判決要件；若欠缺之，則憲法訴願不合法（unzulässig），參閱前述機關爭議之說明。

四、我國規定之得失

地方自治團體有較高權利保障必要者，為針對中央的法律、法規命令或其他具外部效力的規範，而不是限於終審法院之裁判見解。也就是說，我國引進地方自治團體之裁判憲法審查固然也是可以的，但更需要的是法規範之憲法審查。

憲法訴訟法第82條之地方機關提起的爭議涵蓋法規範憲法審查，這於本次修正時已經清楚指明，也可謂「並無規範上之缺漏」，但問題在於其要件過於寬鬆，不無失衡，已如前述。

肆、國家最高機關就下級機關行使職權適用法規範之主動或被動聲請憲法審查

一、規定與理由

憲法訴訟法第47條規定，國家最高機關，「因下級機關行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」（第1項）。下級機關，因行使職權，就所適用之法規範，認有牴觸憲法者，得報請上級機關為前項之聲請（第2項）。其立法理由稱：（一）中央或地方機關適用憲法或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義，得聲請解釋；倘為下級機關聲請，其聲請應經由上級機關層轉。關於層轉，「其作用乃認下級機關遇法規範有違憲之疑義，應由其上級之最高機關作成是否違憲之判斷」⁸⁶。

⁸⁶ 憲法訴訟法第47條立法理由並指出：「基於行政層級上下一體之本質，現行法關於層轉之設計，已無異於由最高機關行使聲請之權責。本次修正爰將聲請主

(二) 國家最高機關之存在，具有追求維護憲政秩序及客觀公共利益之目的，其就下級機關行使職權所遇之法規範違憲疑義，如無法於職權範圍內自行排除者，其得「主動」依本條第一項規定向憲法法庭聲請判決，亦得「被動」依本條第二項之規定向憲法法庭提出聲請。(四) 地方自治團體之行政機關，在體系上屬於行政部門，於辦理中央委辦事項時仍依受上級機關之指揮監督，如其認所適用之法規有牴觸憲法之一，應循本條第二項規定辦理至地方自治團體之行政機關或其立法機關於其辦理自治事項之職權範圍內，認所適用之中央法規有牴觸憲法之疑義，本法另設第7章地方自治保障案件之規定，不在本條範圍內。

以上兩項，旨趣大致相同，指在保障下級機關的法規範憲法審查。前者(主動聲請)乍看之下係出於行政一體及國家最高機關的地位(得聲請釋憲)，無須經下級機關的同意，但這實務上發生的案例可能不多，蓋一般而言行使職權者才有興趣理解與評估認定系爭法規有無違憲。行政院會議有各部會首長及不管部會之政務委員參與，國家最高行政機關於此有可能發現部會所適用的法規有違憲嫌疑，但這畢竟屬於行政院的機制。實務上較有可能發生的，為憲法訴訟法第47條第2項「被動聲請」。

本條所稱下級機關，一方面為中央行政組織基準法所稱「部會、三級機關構-四級機關構」，凡此於德國法稱為「直接行政」，又可稱為「科層式體制下之行政」。二方面為，而這是本文所關注者，地方自治團體所屬機關(其中，地方政府)於執行「委辦事項」之法規範時，德國法將之定性為中央行政機關(部會)所屬的下級機關。我國地方制度法雖然沒有直接規定，但從地方制度法第75條地方行政機關辦理委辦事項係受中央「法令」的拘束以觀，以

體修正為「國家最高機關」，並刪除現行條文關於「層轉」之規定，另增訂第二項，以強化其上下層級關係」。

及從司法院大法官多號解釋中指出上級機關對於地方政府辦理委辦事項所作決定享有合法性與合目的性之監督，應可確立，地方政府於執行委辦事項法律時，性質上為於中央部會所屬的「下級機關」。若地方政府係執行自治條例，則這屬於自治行政，非為主管部會的下級機關。本處所稱適用的法規認有「牴觸憲法者」，應係指稱與地方自治的保障有關的憲法條文。

憲法訴訟法第47條第2項從而係針對委辦事項，地方政府為主管部會的下級機關，非屬自治事項，不得自行提起。就地方自治事項，憲法訴訟法第82條規定，地方行政或立法機關得直接提起，無須報請上級機關層轉。

若地方自治團體執行委辦事項，認為系爭規範的規定過當，以致於侵害其憲法所保障的自治權，例如系爭專業法律沒有將一定的事項劃給地方自治團體作為自治事項，或沒有將一定的事項儘管界定為委辦事項而酌留地方必要的針對地方需求之自主立法空間（日本法稱為「橫出」或「上乘」），或系爭專業法律規定地方政府必須以如何的組織、人事、財務承辦，而相關規定過於嚴苛以致於侵害地方自治團體的自治權。於此所稱自治權係直接或經由論證而可得出，屬於憲法所保障的地方自治權。

問題就在於，若地方自治團體作為下級機關，就所執行的委辦事項法規，有違憲的嫌疑，但上級機關有不同的認定，則這時候依憲法訴訟法第47條第二項，地方自治團體並沒有就監督機關的駁回或不作為提起憲法爭訟的餘地，也不得自行提出。

二、比較法之觀察

德國法並沒有類如我國本條之規定。本文認為，理由不外為，地方自治團體辦理委辦事項而執行有關的法律時，若認為系爭法律有違反憲法地方自治保障規定的嫌疑，則就此得以依據憲法訴訟法

第82條自行提起，不論就係爭的事項究竟定性為自治或委辦事項，蓋即使定性為委辦事項，則系爭法律有無於必要情形下酌留地方針對地方需要而制訂適用於地方之自治條例或委辦規則之空間（日本法稱為「橫出」、「上乘」），或，若系爭專業法律規定地方政府必須以如何的組織、人事、財務而為執行，而相關的規定過於嚴苛以致於侵害憲法就此的地方自治保障。憲法法院於受理本類案件，應區分地方自治團體的「起訴」是否合於憲法訴訟法的要件，於實體上有無理由，則是另一層次的問題。

伍、地方自治團體之聲請統一解釋法令？

我國憲法第78條規定「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，第79條復規定「司法院設大法官若干人，掌理本憲法第78條規定事項」。以上規定，於歷經七次修憲並沒有變更。

一、司法院大法官審理案件法及地方制度法之規定

司法院大法官審理案件法第7條第1項第1款規定地方聲請統一解釋：地方機關，就其職權上適用法律或命令所持見解，與本機關或他機關適用同一法律或命令時所已表示之見解有異者，得聲請統一解釋。但該機關依法應受本機關或他機關見解之拘束，或得變更其見解者，不在此限。

以上規定，性質上為聲請統一解釋法令，而非憲法訴訟，不以法律違憲為理由，也不限於憲法所保障的地方自治權限。其次，其非主觀訴訟，不以憲法或法律所保障之權利或利益受侵害為要件；所稱「地方機關」於解釋上得包括立法與行政機關。第三，若涉及自治事項，則不須取得監督機關之同意，蓋事涉地方自治事項；即使地方自治團體係執行委辦事項（依向來見解，屬於國家事項，地

方自治團體係受國家委託而為辦理，國家機關享有合法性與合目的性之監督)；若系爭規範除了規定委辦事項之外，尚入侵到地方自治團體的自治權限（例如限制地方之組織權、人事權、財政權或專業法律所賦予的自主空間），則地方自治團體也應有權聲請；若系爭領域究為自治或委辦事項存有疑義，則地方自治團體也得聲請，除非顯無理由。以上之範圍過於廣泛，要件過於寬鬆，論者多從統一解釋法令制度之根本必要性切入，指出應嚴格限制⁸⁷。

地制法的地方機關聲請統一解釋規定，並未隨著憲法訴訟法之制定而一併修正或刪除。

二、司法院釋字第 527 號、553 號解釋

司法院釋字第527號、553號於解釋建立若干地方自治團體之救濟管道標準。

87 蘇永欽教授針對統一解釋，質疑「憲政上之妥當性」：首先，爭議性係司法權的主要特徵，統一解釋程序卻是無關權利救濟之單純事宜。其次，司法院作為司法行政機關，所為法令解釋不僅對法官無拘束力；若考量到司法行政權濫用之可能，則更有避免之必要，就此大法官在司法院釋字第137、162號解釋中也已經明確闡明。第三，機關之間在行使職權時，就同一法律發生解釋上的歧異，在所難免；產生歧見的機關之間如有上下之分，下級機關必須受上級機關見解的拘束；真正需要藉助第三者來排除歧見者，係彼此不受拘束之情形，例如行政院與考試院之間，或地方政府與立法院之間。第四，如果機關之間僅就法律如何解釋發生歧見，而還沒有任何具體個案事實顯示確認法律內涵之需要，則立刻交由大法官來統一解釋，反而有「時機是否過早」的問題。第五，即使機關間已經有個案爭議，則此時只要有訴訟權的保障，則應該可以透過法院的裁判加以解決，亦即由法院即可經由裁判釐清法規的內涵。第六，即使終審法院因為分庭以致於有一個法院各自表述的情形，但此時也得依靠終審法院內部的機制來處理即可解決。第七，若將一般機關與法院之見解歧異也當作統一解釋的事由，則不免矮化法院的審判權，置有終局解釋法律之終審法院於何地。第八，由大法官來統一解釋仍具有憲政上正當性者，最多只有兩種情形，一為終審法院之間就實體問題有不同見解，以及不同審判權之間就受理訴訟權限有不同見解。第九，司法院大法官審理案件法於民國82年修定時，沒有積極處理統一解釋法律/命令之制度，不無可惜。蘇永欽，誰統一誰和誰的什麼？——從第668號解釋看大法官統一解釋制度的日薄崦嵫，法令月刊，61卷2期，頁5-12（2010年）。

司法院釋字第553號解釋針對地方政府辦理自治事項之個案監督處置，指出性質上為「行政處分」，地方自治團體若有不服，應循行政爭訟途徑救濟，並無問題。

司法院釋字第527號作成於民國90年6月15日，由臺中市議會提出，案由有二。首先為「有關臺中市政府，未依地方制度法第62條第2項擬定臺中市政府組織自治條例，經臺中市議會同意後，任用佈達副市長，因主管機關內政部對同一法律之釋示（內政部前以臺（88）內民字第八八〇四六五二號函），尚有疑義」，爰依司法院大法官審理案件法第8條第2項之規定，提請統一解釋。其次為，「臺中市議會第十四屆第三次大會在臺中市政府組織自治條例未立法，編制內並無副市長之職稱及配置，即行議決通過副市長之薪資預算，是否違反地方制度法第43條第2項」，而依地方制度法第43條第5項聲請。

本文認為，本號解釋在範圍上不無逾越聲請標的，欠缺比較法之基礎，未審酌我國修憲後之規定。以下區分段落，逐一討論。

（一）就地方法規或地方議會議決事項之監督

本案涉及的法規為：地方制度法第43條第1項至第3項規定各級地方立法機關議決之自治事項，或依同法第30條第1項至第3項決議之地方法規，與憲法、法律、中央法規或上級自治團體自治法規牴觸者無效。發生上述無效情形時，依第43條第4項規定，直轄市議會議決事項由行政院予以函告，縣（市）議會議決事項由中央各該主管機關予以函告，鄉（鎮、市）民代表會議決事項由縣政府予以函告。第43條第5項「第一項至第三項議決自治事項與憲法、法律、中央法規、縣規章有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之」及第30條第5項「自治法規與憲法、法律、基於法律授權之法規、上級自治團體自治條例或該自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之」之規定。

1. 監督機關之聲請解釋

解釋文指出：以上係指對相關業務「有監督自治團體權限之各級主管機關」，對議決事項或自治法規是否牴觸憲法、法律或其他上位規範尚有疑義，而未依相關規定逕予函告無效，向本院大法官聲請解釋而言」。本文認為，這見解有待商榷，蓋監督機關應自行認事用法作成個案決定，其竟然不為而聲請釋憲，欠缺權利保護必要，除非我國為聯邦體制之國家而涉及聯邦體制之爭議處理。

憲法訴訟法第83條已經匡正這個錯誤：其說明欄「二」指出：「……前揭自治監督機關認地方行政機關所辦理之自治事項，有違憲或違法情事，而予以撤銷，涉及各該法規範在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋，屬於有法效性之意思表示，係行政處分……。」

2. 受監督之地方自治團體對函告內容持不同意見

解釋文指出：（1）地方自治團體應視受函告無效者為自治條例抑自治規則，分別由該地方自治團體之立法機關或行政機關，就事件之性質聲請本院解釋憲法或統一解釋法令。有關聲請程序分別適用司法院大法官審理案件法第八條第一項、第二項之規定，於此情形，無同法第九條規定之適用⁸⁸。

本文認為：本處使用「解釋憲法或統一解釋法令」，但二者有別。本案型「函告無效」為上級機關針對個案所作成的監督處置，性質上為行政處分，地方若有爭議，則應循行政爭訟途徑解決。

⁸⁸ 司法院釋字第527號解釋文繼續指出：「（2）至地方行政機關對同級立法機關議決事項發生執行之爭議時，應依地方制度法第三十八條、第三十九條等相關規定處理，尚不得逕向本院聲請解釋。（3）原通過決議事項或自治法規之各級地方立法機關，本身亦不得通過決議案又同時認該決議有牴觸憲法、法律、中央法規或上級自治團體自治法規疑義而聲請解釋」。

(二) 就地方執行個案之監督

這是地方政府執行個案，遭上級機關之個案監督處置撤銷、廢止等，而引發爭議。

1. 上級監督機關聲請

解釋文指出，上級監督機關依地制法第75條對地方行政機關執行自治事項之個案決定，認是否違背憲法、法律或其他上位規範尚有疑義，未依各該項規定予以撤銷、變更、廢止或停止其執行者，得依同條第8項規定聲請司法院解釋。

本文認為，上級機關應自行認事用法作成個案監督決定，其竟然不為而聲請釋憲，顯然欠缺權利保護必要。

2. 地方自治團體聲請

司法院釋字第527號解釋文指出：(1) 地方自治團體之行政機關對上開主管機關所為處分行為，認為已涉及辦理自治事項所依據之自治法規因違反上位規範而生之效力問題，且該自治法規未經上級主管機關函告無效，無從依同法第30條第5項聲請解釋，自治團體之行政機關亦得依同法第75條第8項逕向本院聲請解釋。(2) 其因處分行為而構成司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款之疑義或爭議時，則另得直接聲請解釋憲法。(3) 如上述處分行為有損害地方自治團體之權利或法律上利益情事，其行政機關得代表地方自治團體依法提起行政訴訟，於窮盡訴訟之審級救濟後，若仍發生法律或其他上位規範違憲疑義，而合於司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款之要件，亦非不得聲請本院解釋。

就(1)，本文認為：於此上級機關已經作成監督處置，地方政府應循行政爭訟途徑解決，於爭訟中得一併主張系爭自治法規與上為規範之適用，而無必要如解釋文所稱「應限於上級主管機關之處

分行爲已涉及辦理自治事項所依據之自治法規因違反上位規範而生之效力問題，且該自治法規未經上級主管機關函告無效，無從依同法第30條第5項聲請解釋之情形」之「依第75條第8項逕向司法院聲請解釋」。除此之外，對於上級機關個案監督處置竟然得直接聲請釋憲，在單一國毫無可能，參見前述德國法之說明。

就（2），其指出若該當司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款之疑義或爭議時，「則另得直接聲請解釋憲法」，亦即，地方政府得直接提起機關爭議，而與本處之聲請釋憲平行，憲法訴訟法第82條繼續維持之。本文認為，德國機關爭議權限於憲政機關間，地方機關不享有之，我國規定不無可商榷之處。

就（3），上級監督機關作成撤銷、變更、廢止或停止執行之決定，地方政府於窮盡訴訟途徑後，解釋文指出，至於因上級主管機關之處分行爲有損害地方自治團體之權利或法律上利益情事，若仍發生「法律或其他上位規範違憲疑義」，而合於司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款之要件，亦非不得聲請司法院解釋。

本文認為：本段肯認司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款「對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者」，係採法規範之憲法審查，堪稱妥當。我國憲法訴訟法與此有二處不同：首先，憲法訴訟法第83條限於三種自治監督情形而且只開放「裁判憲法審查」。其次，憲法訴訟法於第83條專門規定地方自治團體之裁判憲法審查，與第59條人民聲請者區隔，蓋前者並非自然人，並不享有基本權之保障（儘管制度保障說也係賦予主觀公權利之地位，參見前述德國法，以及前言中我國法之說明），兩者性質不同，所以另有專門的條文。

（三）就非屬前述事項

這是指「無關地方自治團體決議事項或自治法規效力問題，亦

不屬前開得提起行政訴訟之事項，而純為中央與地方自治團體間或上下級地方自治團體間之權限爭議」。解釋文指出，「則應循地方制度法第七十七條規定解決之，尚不得逕向本院聲請解釋」。

本文認為，地方政府與上級機關之關係，不外為地方辦理自治或委辦事項之受到監督，以及上級機關依法律完成有關施政而有影響地方權益之情形，例如上級政府制訂區域計畫、各種保育型之計畫、重大開發案之個案決定。本段解釋文所稱爭議及解決機制，不無漏未斟酌前述後者。原則上，這些仍屬於行政法層次之爭議，分為法規命令或其他具外部效力之規範及行政處分，地方政府若認為權益受到侵害，則應行政爭訟途徑解決。

(四) 小結

以上顯示，首先，司法院釋字第527號解釋欠缺比較法之基礎，單以地制法、司法院大法官審理案件法之規定為依據，尤其地方機關得直接聲請釋憲之命題，顯未針對我國七次修憲後之體制，有所不妥。其次，「有監督自治團體權限之各級主管機關」對個案中地方議決事項或自治法規是否牴觸憲法、法律或其他上位規範認為尚有疑義，本文認為，其得自行認事用法作成個案決定，竟不為而聲請釋憲，不無欠缺權利保護必要。第三，就地方政府於窮盡訴訟途徑後之救濟，其採法規範憲法審查，但憲法訴訟法卻改採裁判憲法審查⁸⁹。第四，其未處理上級機關依法律授權完成有關施政而影響地方權益之案型，這非針對地方自治之監督，而是上級政府的施政。

89 憲法訴訟法第83條理由欄(三)指出：「地方自治團體既係基於憲法所保障之地方自治權受侵害，『類同於人民憲法所保障之基本權受侵害』(引號為本文所加)，而得提起行政爭訟，則於其用盡審級救濟途徑，仍受有不利之確定終局裁判之情形下，應許其類同於人民之地位，聲請憲法法庭為裁判憲法審查。憲法訴訟法第59條的爭執標的為『不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判』」。

三、憲法訴訟法之規定

憲法訴訟法第八章為「統一解釋法律及命令案件」。憲法訴訟法第84條規定：人民就其「依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判適用法規所表示之見解，認與不同審判權終審法院之確定終局裁判適用同一法規已表示之見解有異」，得聲請憲法法庭為統一見解之判決（第1項）⁹⁰。以上顯示，本條並不包括地方機關之聲請。

憲法訴訟法第1條第2項規定，其他法律規定得聲請司法院解釋者，其聲請程序應依其性質，分別適用解釋憲法或統一解釋法律及命令之規定。言下之意，不排除其他法律規定相關主體得提起憲法訴訟，而地方制度法第30條第5項（自治法規與憲法、法律、基於法律授權之法規、上級自治團體自治條例或該自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時）、第43條第5項（直轄市議會議決自治事項發生與憲法、法律或基於法律授權之法規有無牴觸有無牴觸疑義時）、第75條第8項（各級政府辦理自治事項經監督處置發生有無違背憲法、法律、中央法規、縣規章發生疑義時）屬之。說明欄「三」也指出：衡諸地方自治團體應受憲法制度保障，惟亦衡諸憲法設立釋憲制度之本旨，主要係授予釋憲機關從事規範審查權限，且基於釋憲機關之最後性，尚不及於具體處分違憲或違法之審理，是地方自治團體就其與自治監督機關因地方自治事項監督權之爭議，雖地方制度法第30條第5項、第43條第5項及第75條第8項之規定有得聲請司法院解釋之規定，惟依本法第1條第2項之意旨，其聲請程序應依其性質，適用所應依循之聲請解釋憲法之程序。問題在於，憲法訴訟法之聲請統一解釋規定並不包括地方機關，已如前述。所稱「適

⁹⁰ 憲法訴訟法第84條第2、3項規定：「前項情形，如人民得依法定程序聲明不服，或後裁判已變更前裁判之見解者，不得聲請。第一項聲請，應於該不利確定終局裁判送達後三個月之不變期間內為之。」

用解釋憲法之規定」，應係指稱憲法訴訟法所明文規定者。

陸、就審查所依據的憲法條文與控制密度

這問題得依據不同的憲法訴訟類型而有區別，但也得總體而為觀察。

一、德國法

憲法法院的審查依據，為「憲法之地方自治保障條文」。解釋上，端視當事人之起訴主張，也得包括進一步「對於地方自治得以一併產生影響之憲法規定」(das Bild der Selbstverwaltung mitzubestimmen geeignete Verfassungsnormen)，例如憲法上之民主原則（例如中央於制定法律或法規時地方立法或行政機關之參與不足）、平等原則（中央法規對於不同層級、規模或類型之地方自治團體未細緻考慮，而過於籠統）、民生福利國原則等⁹¹。

其次，有關憲法法院之「控制密度」(Kontrolldichte)：控制密度與系爭案件所侵害之憲法規定之性質、重要性有關，也與干預之嚴重性有關，以下只能作一般討論。

德國法於此「制度保障說」之下，建立憲法地方自治保障之「核心領域」(Kernbereichsschutz)與「外圍領域」(Randbereichsschutz)之理論。核心領域係不得被入侵，若系爭干預措施侵害之，則該當違憲；反之，就外圍領域而言，國家的干預並非當然違憲，但須合於比例原則；地方自治團體所享有者為制度保障，在法律的框架範圍內，立法者有相當的形成權；針對國家與地方之權限劃分，這是一種「制度保障說」之下的「職掌劃分上之合

⁹¹ Vgl. *Starke* (Fn. 62), S. 323 f.

於比例性之審查」，與個人基本權保障之審查所稱「比例原則」不同。即使於此在討論的步驟上，得採行基本權保障有關之審查架構（須出於公共利益始得干預，干預的目的必須正當，手段必須適當、必要且合於狹義之比例原則），憲法法院於進行違憲審查時須自我節制⁹²。

就核心與外圍領域，因劃分結果之法律效果差距頗大，所以總不免引起爭議，實務上顯少承認相關干預措施已經涉及核心領域。聯邦憲法法院在判決中指出，所謂地方共同體的事項，亦即「自治事項」，係指稱係植基於地方共同體之需要與利益，地方共同體就之有一個特別關聯性，其對地方自治團體之所有的居民而言，係對其共同的生活與居住有所關聯者⁹³。於此，因連結到「轄區」、「居民」，立法者從而得衡量經社與科技變遷，但同時也應衡量歷史以來地方所承辦的自治事項類型情形，除此之外，地方的規模大小也可納入衡量之中。當邦立法者將原屬地方自治團體的業務權責，移轉給上級地方自治團體辦理（而可謂剝奪地方自治事項），聯邦憲法法院還是以德國基本法第28條第2項用詞「地方共同體之事項」作為依據，指出重點在於系爭事務的性質，亦即其是否出於地方居民的需要與利益，亦即其與地方居民關聯性的高低，而非取決於地方自治團體（因規模太小而沒有充分）的行政力（*Verwaltungskraft*），就此立法者享有裁量空間⁹⁴。

就憲法法院的違憲審查標準高低，學者指出，就邦立法有關自治事項、委辦事項的劃分，或將地方自治團體原享有的業務權責移轉到上級之決定，因德國基本法第28條第2項明白規定地方自治團

⁹² *Burgi* (Fn. 63), § 6 Rn. 14 f., 35-45; *Gern* (Fn. 64), Rn. 78-82; *Starke* (Fn. 62), S. 324. 就比例性審查的說明，參見*Burgi*, a.a.O., Rn. 39 f.

⁹³ *Burgi* (Fn. 63), § 6 Rn. 14 ff.

⁹⁴ *Burgi* (Fn. 63), § 6 Rn. 14 ff.; *Hartmut Maurer*, *Verfassungsrechtliche Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung*, DVBl. 1995, S. 1037 (1043 ff.).

體就地方共同體事項，享有原則性的管轄權，所以相關的違憲審查不能停留在恣意性之審查，但也不是一種高內容強度的審查，而是停留在一種可支持性的審查基準（*Vertretbarkeit*）⁹⁵。本處的違憲審查涉及制度保障，從而整體性而言低於個人基本權之遭受干預的違憲審查；本處所稱的「可支持性審查標準」，低於個人基本權有關之「中度審查基準」。在有關邦立法者將鄉鎮市的業務權責移轉給上級自治體時，憲法法院的審查上總認為，只要系爭權限移轉規定已經有一定的類型化的劃分，而不是將地方自治團體不加細分地只以一種而為設計，若法律已有一些緩和化的規定，例如縣得於一定要件下將業務權責再度委託予鄉鎮市，或就該任務仍保留若干次要、細微部分予鄉鎮市，便可通過違憲審查⁹⁶。以下舉例說明。

聯邦憲法法院於1988年作成著名之「羅斯提德案判決」，迄今仍為標準版本。本案的緣起，為下沙克森邦修改邦廢棄物清理法，將原先屬於鄉鎮市承辦的廢棄物清除處理之管轄權改由縣承擔，但經由鄉鎮市之申請，縣得決定是否將縣新取得的管轄權以「義務承辦而上級無指令權之事項」（*weisungsfreie Pflichtaufgabe*；按，類如我國地方制度法第2條所稱「法定自治事項」），而授權鄉鎮市辦理。本案經由地方自治團體之憲法訴願而提出。判決指出，基本法第28條第2項規定，「對於地方共同體之所有事項，鄉鎮市於法律的框架下享有以自我責任規定之權」，其所建立鄉鎮市的自治保障，須經由法律加以規定。所謂「在法律的框架內」，係指稱「法律保留」，賦予立法者作成有關的形成規定，但這個形成與規定的權力均不得任意。聯邦憲法法院接著提出鄉鎮市自治保障之「核心領域」與「非核心領域」。自治事項之劃定，並不取決於鄉鎮市的行政力（*Verwaltungskraft*）。鄉鎮市自治事項並不是一個一次便得永遠確認範圍之任務領域；對於不同人口、土地面積與結構的鄉鎮市而

⁹⁵ *Burgi* (Fn. 63), § 6 Rn. 44.

⁹⁶ *Burgi* (Fn. 63), § 6 Rn. 44.

言，其也不必相同。若某一任務具有地方共同體相關的性格，則立法者只能出於公共福祉的理由（*nur aus Gruenden des Gemeininteresses*），加以剝奪。反之，只是單純之行政簡化或管轄權集中之理由（目標），例如為了公共行政之一致性（*Interesse der uebersichtlichkeit*），則尚不能正當化之；來自「公共行政經濟性與節約性之理由」亦然。就是否及如何程度具體的任務，係構成地方共同體的任務事項，必須加以細分，也取決於相關鄉鎮市大小，於此立法者應經由有關事務的標準，並取向系爭任務合於秩序性的履行要求，而加以決定。就有關的決定，立法者享有「評估餘地」（*Einschaetzungsspielraum*）⁹⁷。立法者不須將一個任務所有個別面向，也無須對於每一個鄉鎮市當作自治事項，毋寧，其得將某一任務劃為「較大規模的城市」之自治事項，或就該任務的某面向界定為鄉鎮市自治事項，而對於其餘則界定「超越個別地域」（*ueberoertlich*）之性質。在此範圍內，立法者得進行「類型的建構」（*typisieren*）。就本案，聯邦憲法法院認為系爭邦法規定合憲。邦立法者於本件中之修法移轉管轄，與「聯邦廢棄物清除處理法」的規定相一致，係出於更好的環境保護理由，其次的理由在於傳染病的防止（*Seuchenabwehr*）及景觀維護（*Landschaftspflege*）。以上屬於公共福祉，且在評價上具有高度意義；除此之外，環境保護與傳染病防護等，於聯邦水利法、聯邦傳染病防治法、營業管制法等也有若干規範，且都強調危險防禦之屬性。本件中，系爭業務在邦轄市仍由邦轄市承辦，在縣之鄉鎮市則原則上移轉管轄，但鄉鎮市得經由申請縣許可而得受委託承辦，此已經設想到較大規模城市之需要。本次修法包括家用廢棄物的收集與運送。

因垃圾量與危險廢棄物增加、廢棄物清除處理設施因數量減少、運送距離較遠所致運送質量提升要求等，以及必須確保有關任

97 BVerfGE 79, 127 = NVwZ 1989, S. 347 (350).

務合於秩序的承辦，所以相關修法難謂沒有可支持性，立法者也已經規定鄉鎮市得經由申請而受委託承辦。

其次，有關邦法律是否過度入侵到地方自治團體以自我責任辦理自治事項的問題上，例如有關地方自治團體的組織權、人事權、計劃權等，聯邦憲法法院也採可支持性的審查（Vertretbarkeitskontrolle）⁹⁸。於此得以聯邦憲法法院1994年10月26日「邦兩性平權行政監察官設置法」判決，略作觀察⁹⁹。本件由兩個鄉鎮市提起，訴訟標的為許列什維茲－霍斯坦邦鄉鎮市自治法第2條第3項。依之，為促成男性女性基本權之平等保障，凡鄉鎮市具有自主之行政組織者，必須設置「兩性平權監察官」（eine Gleichstellungsbeauftragte）；凡鄉鎮市人口超過10萬人以上者，其所設置的兩性平權監察人必須為全職工作人員；詳細情形由各鄉鎮市基本章程加以規定；各鄉鎮市應於基本章程中一併規定，兩性平權監察官於行使職權時享有獨立地位，而且有權參與鄉鎮市民代表大會與委員會；凡屬該監察人的職掌事項，出於該監察人的要求，此等會議應提供其發言機會；經由鄉鎮市議會議員二分之一表決，得撤換兩性平權監察人選。當事人提起「地方自治團體憲法訴願」，主張系爭規定侵犯聯邦基本法與邦憲法所保障地方自治中之組織高權與人事高權。判決主要指出：1. 基本法第28條第2項第1句所保障之地方自治，為地方「以自我責任」承辦任務，而這當中的一項內涵，為地方必須享有一定之組織設置上自主決定空間，否則如何稱為「以自我責任」（in eigener Verantwortung）。但另一方面，基本法所保障的地方自治，係「在法律的框架下」（im Rahmen der Gesetze），立法者對地方自治團體組織制頒規定，從而並無不可，但須注意地方以

⁹⁸ Burgi (Fn. 63), § 6 Rn. 45.

⁹⁹ Vgl. BVerfGE 91, 228, online verfügbar unter https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1994/10/rs19941026_2bvr044591.html（最後瀏覽日：2019年5月27日）。

自我責任承辦之界線。2. 就國家針對地方政府組織之規定而言，立法者於此不必針對各個地方自治團體為個別的考量，而得進行類型化（Typisieren）的嘗試，得區分不同等級（例如以人口為基礎），邦立法者不須對各別鄉鎮為精確規定，原則上也不須針對就整體而言不具重要意義的部分加以關照，這也是立法係針對通案規範之特性使然。本件中，系爭規定只是對於地方政府一般行政組框架作出點狀式安排，並不窒息地方行動空間；相關的立法例也見諸「地方審計組織（Rechnungsprüfungsamt）」、「地方外國人事務諮詢委員會」（Ausländerbeirat）等。系爭規定已經將地方自治團體分類，而且只針對人口達10萬人以上的鄉鎮市；就設置具體的安排，例如成立一個局處或科（課），或只是以單一個人而隸屬於鄉鎮市公所秘書處，或鄉鎮市公所之市長辦公室等，係由相關鄉鎮市自行決定，從而也可謂已經留下必要的組織權空間¹⁰⁰。

二、我國法

以上德國法之理論，於我國也得適用。憲法法庭的審查標準，為憲法有關地方自治保障之規定，亦即憲法第107條以下有關地方自治的保障，及憲法增修條文第9條。解釋上，若參照德國法的判決與學說，則也得包括憲法上之民主原則（例如中央法規制定時地方立法或行政機關參與不足）、平等原則（中央法規所謂規定對於不同層級、規模或類型之地方自治團體未充分考慮，而過於籠統）、民生福利國原則等，但以憲法地方自治保障條文作為直接與主要。

其次，一般而言，因涉及制度保障，而非個人基本權，立法者有形成的空間，憲法法庭應自我節制。

¹⁰⁰ Vgl. Ingrid Alice Mayer, Verpflichtung der Gemeinden zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten, NVwZ 1995, S. 663 (663 ff.).

第三，我國也已出現相同的論證架構：司法院釋字第550號解釋針對「全民健康保險法」之責地方政府補助保費之規定，是否違反憲法地方財政保障，解釋文採用制度保障說、法律保留原則、非核心領域、憲法無明文規定、立法裁量，指出「除顯有不當者外，不生牴觸憲法之問題」。

柒、結語

地方自治團體享有憲法上「制度保障說」地位。其中一項內容，為憲法訴訟權。我國原規定於司法院大法官審理案件法、地方制度法，晚近三讀通過之憲法訴訟法有意統整作出新一代的規定。

憲法訴訟法第82條規定之地方自治團體之立法或行政機關之規範違憲審查訴訟，而且以「有侵害之虞」為要件。理由欄，「性質屬法規範憲法審查」、「類似本法第47條國家最高機關聲請案件」，就後者而言不無違失，蓋機關爭議係憲政機關得直接提起，無須窮盡訴訟途徑；地方立法或行政機關非憲政機關，相關爭議之政治性低，不會動搖國本；聯邦國家中之聯邦與邦之間或邦與邦之間的爭議也採直接起訴，但我國不是聯邦體制。整體而言，本條有諸多不通之處。

其次，就地方自治團體之裁判憲法審查而言：1. 參照德國法個人憲法訴願，必須是專業法院於解釋實定法出現一個基於對於基本權意義之原則性不正確之見解，尤其有關基本權的保障範圍及其實質意義之錯誤，而且該錯誤必須具一定之比重，憲法法庭始得審查。2. 地方自治團體有較高權利保障必要者，為針對中央的法律、法規命令或其他具外部效力的規範，而不限於終審法院裁判見解，德國法的實踐顯示絕大多數案件係針對法律，本條立法政策非無可檢討之處。3. 地方自治團體只能針對「中央對地方自治事項監督」

的三種類型，也無必要。

第三、憲法訴訟法第47條規定國家最高機關就下級機關行使職權適用法規範之主動或被動聲請憲法審查。德國法沒有類似規定，理由不外為，地方自治團體辦理委辦事項時，若系爭法律未斟酌地方需要而授予制訂適用於地方之法規之空間（日本法稱為「橫出」、「上乘」），或，若系爭專業法律規定地方政府必須以如何的組織、人事、財務而為執行，而相關的規定過於嚴苛時，地方得以侵害憲法的地方自治保障為由起訴。

第四，就地方自治團體聲請統一解釋法令而言，憲法訴訟法沒有規定之，從而不再採行。

第五，地方自治團體享有制度保障，具客觀法制度與主觀法地位之性質。地方自治團體得就團體權利受侵害提起行政爭訟，並於窮盡訴訟途徑後，針對確定裁判所依據的法規範提起違憲審查之訴訟，例外時得直接起訴，凡此即為德國法之「地方自治團體之憲法訴願」，性質上為「主觀訴訟」。

第六，就憲法法庭之審查依據，應以憲法地方自治保障規定為直接與主要，視當事人的主張也得涵蓋其他條文。憲法法庭的控制密度應予調降。蓋這涉及「制度保障」，屬於地方制度之立法形成但不得違反憲法上之保障地位，而非個人之基本權，德國法採之。

地方自治團體的保障，其中之行政爭訟保障與憲法訴訟保障，為 吳庚教授及學界所關注。隨著我國民主化、法治化、地方自治化的發展，相關爭訟案件質量將會增加。吾人於緬懷 吳庚教授時，得對憲法訴訟法的規定與釋義，隨分隨力有所參與。

參考文獻

1. 中文部分

- 吳庚、張文郁(2016)，行政爭訟法論，修訂8版，臺北：元照。
- 吳庚、陳淳文(2017)，憲法理論與政府體制，增訂5版，臺北：自版。
- 吳信華(2005)，論地方自治團體的聲請釋憲，政大法學評論，87期，頁133-190。
- (2014)，地方自治團體對中央監督行為的爭訟途徑，台灣法學雜誌，240期，頁95-101。
- 蘇永欽(2001)，地方自治法規與人民權利義務，收於：臺北市政府法規委員會編，地方自治法2001，頁135-162，臺北：臺北市政府法規委員會。
- (2010)，誰統一誰和誰的什麼？——從第668號解釋看大法官統一解釋制度的日薄崦嵫，法令月刊，61卷2期，頁4-20。

2. 外文部分

- Bethge, Herbert (2014), in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Lfg. 45 Dezember 2014, München: C. H. Beck, § 91.
- (2018), in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Lfg. 53 Februar 2018, München: C. H. Beck, § 90.
- Burgi, Martin (2012), Kommunalrecht, 4. Aufl., München: C. H. Beck, § 6.
- Degenhart Christoph (2013), Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 29. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.

- Dombert, Matthias (2009), Wenn's ums Geld geht: kommunale Finanzhoheit und die Zulässigkeitsvoraussetzungen des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes, LKV, S. 343-350.
- Geis, Max-Emanuel (2014), Kommunalrecht, 3. Aufl., München: C. H. Beck.
- Geis, Max-Emanuel/Meier, Heidrun (2011) Grundfälle zum Organstreitverfahren, Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 ff. BVerf GG, JuS, S. 699-704.
- Gern, Alfons (2003), Deutsches Kommunalrecht, 3. Aufl., Baden-Baden: Nomosgesellschaft.
- Hopfauf, Axel (2008), in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 11. Aufl., München: Carl Heymanns, Art. 93.
- Hufen, Friedhelm (2013), Verwaltungsprozeßrecht, 9. Aufl., München: C. H. Beck.
- Jarass, Hans Dieter/Pieroth, Bodo (2014), in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 13. Aufl., München: C. H. Beck, Art. 93.
- Kaplonek, Benno (2005), Die Normenkontrolle auf kommunalen Antrag vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, LKV, S. 526-532.
- Maurer, Hartmut (1995), Verfassungsrechtliche Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung, DVBl, S. 1037-1046.
- (2010), Staatsrecht I: Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, 6. Aufl., München: C. H. Beck.
- Mayer, Ingrid Alice (1995), Verpflichtung der Gemeinden zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten, NVwZ, S. 663-664.
- Morgenthaler, Gerd (2019), in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, 42. Edition, Stand: 01.12.2019, München: C. H. Beck,

Art. 93.

Roze, Jochen (2017), in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Stand: Lfg. 52 September 2017, München: C. H. Beck, § 76.

Rüchardt, Corinne (2017), „Strafbare Satire?“ Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Urteilsverfassungsbeschwerde, JA, S. 514-522.

Schlaich, Klaus/Korioth, Stefan (2018), Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 11. Aufl., München: C. H. Beck.

Schmidt, Thorsten Ingo (2008), Die kommunalverfassungsbeschwerde, JA, S. 763-772.

Starke, Thomas (2008), Grundfälle zur Kommunalverfassungsbeschwerde, JuS, S. 319-324.

Voßkuhle, Andreas/Kaiser, Anna-Bettina (2017), Die Ausführung von Bundesgesetzen-Verwaltungskompetenzen, JuS, S. 316-318.

Zuck, Rüdiger (2017), Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 5. Aufl., München: C. H. Beck.